InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO

WWW. INDRET.COM

La ordenación conjunta de la sucesión de los cónyuges ¿Heredamiento preventivo o testamento mancomunado?

Joan Egea Fernàndez
Catedrático de Derecho civil
Universitat Pompeu Fabra

BARCELONA, ABRIL 2015

Abstract

Los cónyuges catalanes suelen ordenar su sucesión otorgando cada uno su propio testamento, de forma simultánea y con idéntico contenido, prácticamente como si se tratara de un único negocio jurídico mortis causa. *Ante ello, la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, consideró oportuno posibilitar que, efectivamente, pudieran disponer de sus bienes de forma conjunta y revocable, pero no lo hizo, como hubiera sido de esperar, mediante la admisión del testamento mancomunado, sino que optó por diseñar un nuevo modelo de heredamiento preventivo. En el presente trabajo, después de examinar los regímenes jurídicos que caracterizan ambos instrumentos sucesorios, se concluye que las diferencias no son sustanciales y que, efectivamente, con la regulación actual, los heredamientos preventivos con pluralidad de causantes pueden asumir la función que correspondería al testamento mancomunado. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley demuestra, sin embargo, que el número de heredamientos sigue siendo insignificante y que, a la vez, siguen proliferando los testamentos individuales en los que los cónyuges otorgan disposiciones correspectivas. Es decir, los testadores no perciben que sea lo mismo otorgar un heredamiento preventivo que testar conjuntamente, y no es inverosímil pensar que, si la misma regulación que hoy se da al heredamiento mutual preventivo hubiera recibido el nombre de* "testamento mancomunado", *el número de disposiciones conjuntas sería mucho mayor.*

Catalan spouses usually make their wills simultaneously and with the same content in order to give and bequeath each other as sole heirs, almost as if it was a single mutual will. In response, Law 10/2008, of 10 July, of the fourth book of the Civil Code of Catalonia, regarding successions, considered appropriate to enable such joint bequeathing of their property, even though the law did not articulate it, as it was desiderable, as a joint and mutual will but as a revocable contract upon a future succession, a new model of preventive inheritance pact. After reviewing the legal regimes that characterize both inheritance instruments, the paper concludes that the differences are not substantial and that, indeed, under the current regulation, preventive inheritance pacts with several testators work as a joint and mutual will. In practice, however, since the entering into force of the Law 10/2008 the number of preventive inheritance pacts concluded is still very low and testators prefer to make two different single wills where the spouses bequeath each other as sole heirs. The lack of identification, among testators, between preventive inheritance pacts and mutual wills suggests the possibility that the former terminology would have been much more appealing and the number of such wills would be much higher.

Title: The joint planning of spouses' inheritance. Preventive inheritance pact or mutual will?

Palabras clave: pactos sucesorios, sucesión contractual, heredamiento mutual, testamento mancomunado, heredamiento preventivo, revocación, derecho civil catalán

Keywords: succession agreements, mutual inheritance pact, preventive inheritance pact, revocation, Catalan civil law

Sumario

1. Introducción
2. Los testamentos pluripersonales en la tradición jurídica catalana
3. Las propuestas de regulación del testamento mancomunado en el derecho catalán
4. La funcionalidad del heredamiento preventivo como testamento mancomunado. Similitudes y diferencias entre ambos
4.1. Consideraciones generales
4.2. Modalidades de heredamiento preventivo con pluralidad de causantes
4.3. Legitimación y capacidad
4.4. Requisitos de forma
4.5. Contenido
4.6. Causas de ineficacia: nulidad, revocación y crisis matrimonial o de pareja
4.7. Limitación de las facultades dispositivas en vida del causante
5. Consideraciones conclusivas
6. Bibliografía

1. Introducción

La práctica notarial pone de manifiesto que muchos cónyuges catalanes, y también convivientes en pareja estable, suelen acudir al notario para otorgar testamento el mismo día y a la misma hora, a menudo en números de protocolo sucesivos y, en ocasiones, asistiendo incluso cada uno al acto de otorgamiento del otro, de manera que no es extraño que algunos puedan llegar a creer, erróneamente, que las dos declaraciones forman parte de un único acto testamentario. Al respecto, precisamente, los propios notarios han señalado la sorpresa que manifiestan estas parejas, que no entienden porque, queriendo favorecerse mutuamente con una institución recíproca, no pueden otorgarla en el mismo documento[1].

Efectivamente, lo más común es que se instituyan mutuamente herederos con sustitución vulgar a favor de los hijos comunes, aunque, en ocasiones, se añade la cláusula según la cual, a la muerte del cónyuge sobreviviente, el remanente de los bienes que integraban la herencia del premuerto y de los que no hubiera dispuesto pasará a los mencionados hijos. Se trata de una forma de hacer que demuestra una clara voluntad de ordenar la sucesión de forma concertada y armónica, aunque no se puede perder de vista que estamos ante de dos testamentos diferentes, que tienen vida propia y, por lo tanto, que cada uno puede ser revocado independientemente y sin que el otro otorgante se llegue a enterar.

La realidad que acabamos de describir se entiende mejor si se tiene en cuenta que, desde hace ya bastante tiempo, los patrimonios familiares ya no están vinculados a «la casa», entendida como unidad de explotación agraria, sino que los recursos de las familias derivan fundamentalmente del trabajo de sus integrantes y se destinan a satisfacer las propias necesidades, más que a la acumulación para las futuras generaciones. Quiero decir que esta nueva realidad económica se ha reflejado en el tipo preponderante de disposición sucesoria, que actualmente se caracteriza, como decía, por el predominio de las instituciones recíprocas de heredero entre cónyuges, en las que los hijos acostumbran a quedar en un segundo plano. Dicho de otra manera, el patrimonio conseguido durante la convivencia ya no tiene como destino mayoritario su transmisión a la descendencia sino que, en un momento en que la esperanza de vida es cada vez más elevada, se opta por asegurar el sostén económico de la pareja y, llegado el momento, del sobreviviente[2].

El legislador catalán ha querido dar cobertura jurídica a esta nueva realidad que lleva a que las parejas soliciten poder disponer conjunta y coordinadamente de su patrimonio hereditario en un mismo acto y con posibilidad de revocación. Ahora bien, evidenciando aun una especie de desconfianza hacia el testamento mancomunado o conjunto, no lo ha hecho mediante la incorporación de esta figura testamentaria –que, en principio y de forma natural, se podría considerar el instrumento más idóneo–, sino que ha optado por dar una nueva configuración a los pactos sucesorios, concretamente al heredamiento preventivo, posibilitando que, con un diseño adecuado, pueda ocupar el lugar de aquel.

---

[1] Así lo habían hecho notar, ya hace bastantes años, SANTDIUMENGE FARRÉ (1994, p. 440) y GARRIDO MELERO (1997, p. 490).

[2] Cf., en este sentido, la experiencia profesional que relata el notario ESQUIROL JIMÉNEZ (2008, p. 101).

En síntesis, el derecho catalán vigente, aunque no lo formula de manera expresa, ha optado por mantener la prohibición del testamento mancomunado[3]. Así se desprende, en efecto, de la misma regulación del testamento que contiene el Código civil de Cataluña, que se caracteriza por ser un negocio jurídico unilateral, individual, personalísimo, solemne y esencialmente revocable. De hecho, fue la elevación a la categoría de dogma del mencionado carácter individual lo que, en el derecho español, ya hace más 125 años, supuso que el art. 669 del Código civil prohibiera expresamente este tipo testamentario y, por influencia de este, que en el derecho catalán se entendiera que tampoco cabía. No hace falta decir que el testamento mancomunado se aparta de esta concepción individual, ya que lo otorgan dos o más personas en un solo acto o instrumento formal con carácter revocable, unitario e indivisible, en el que manifiestan la última voluntad respecto del destino de sus respectivos patrimonios para después de la muerte[4]. Y esto, con independencia de que lo hagan en cláusulas separadas para cada testador o en una sola que contenga la expresión de la voluntad sucesoria de todos ellos, como sucede a menudo con las instituciones recíprocas de heredero.

Son dos las razones que, tradicionalmente, se suelen aducir para prohibir el testamento con pluralidad de otorgantes. La primera se refiere a la posible afectación de la libertad de testar, en el sentido que se ha podido considerar que el hecho de que un testador conozca el contenido de la declaración del otro puede facilitar la captación de voluntad e inducirle a testar en un determinado sentido. Se trata de un argumento que, en mi opinión, es inconsistente, ya que las presiones para testar no dependen del hecho de que las declaraciones de voluntad se hagan en un mismo acto o separadamente, aparte que es una obviedad que a la hora de disponer *mortis causa* nadie deja de tener presente de qué manera el círculo familiar recibirá su voluntad sucesoria. Todo ello, por no decir que no es nada raro que el testador otorgue el testamento condicionado, precisamente, por este juicio de previsibilidad[5]. Sea como fuere, parece excesivo que la solución adoptada para evitar las captaciones de voluntad haya consistido en prohibir absolutamente esta forma testamentaria, descartando, por consiguiente, la posibilidad de admitirla con ciertos condicionantes que, como la exigencia de la intervención notarial, fácilmente habrían permitido garantizar la mencionada libertad de testar.

La otra razón que se alega para rechazar el testamento mancomunado hace referencia al hecho de que, dado que la revocación es una característica esencial de cualquier testamento, no está claro

[3] Ya con la entrada en vigor del Código de sucesiones, el año 1991, la doctrina había criticado que se hubiera dejado pasar la oportunidad de introducir este nuevo testamento en el ordenamiento catalán (SANTDIUMENGE FARRÉ, 1994, p. 439). Años después vemos reproducida esa misma crítica en relación con el libro cuarto, en SALVADOR CODERCH/LÓPEZ BURNIOL (2009, p. 70), aunque admiten que la nueva configuración del heredamiento preventivo –revocable unilateralmente con notificación notarial (art. 431-21 CCCat) − ha venido a llenar este vacío formal.

[4] V., por ejemplo, la definición que hace el artículo 3 c) del Reglamento (UE) nº. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones *mortis causa* y a la creación de un certificado sucesorio europeo, donde se concibe como «el testamento otorgado en un acto por dos o más personas».

[5] Cf., en este mismo sentido, la crítica que hace ALBALADEJO (1990, p. 108), donde destaca que las presiones se dan en muchos casos y se seguirán dando con testamento mancomunado o sin él.

que califique también este tipo testamentario, ya que la línea que lo separa de los contratos sucesorios —por definición irrevocables— es difusa. Se considera que admitir la revocación en vida del otro otorgante, sin que tenga conocimiento de ello, podría constituir una frustración de la natural expectativa de este. Y lo mismo para el caso de que la revocación se produjera después de haber muerto uno de ellos, si las disposiciones que el premuerto había otorgado se habían hecho teniendo en consideración las que en aquel mismo testamento había hecho el cotestador.

De ahí que se haya podido entender que, como que la mejor manera de garantizar que el sobreviviente respetará la confianza que deriva del carácter recíproco o correspectivo de las estipulaciones es configurar el testamento mancomunado como irrevocable una vez haya muerto uno de los testadores, eso supone cambiar la naturaleza y otorgarle los efectos propios del contrato sucesorio. Ahora bien, no me puedo privar de llamar la atención, porque evidencia una cierta incoherencia, sobre el hecho de que el ordenamiento catalán, que, a través de los heredamientos, admite que los cónyuges puedan pactar con carácter irrevocable la disposición conjunta de las respectivas herencias, hubiera acabado interiorizando, arrastrado por el Código civil español, que no puedan hacer lo mismo, pero con carácter revocable[6].

La Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, pretende salvar estas objeciones, pero, como decía, no lo ha hecho a través del camino, más sencillo, de incluir directamente una regulación de los testamentos mancomunados, sino que ha preferido dar un rodeo y adaptar los heredamientos para que puedan cumplir esa misma función. Concretamente, ha dado un nuevo perfil al heredamiento preventivo, cuya característica más destacada es que –como el testamento–, una vez otorgado, se puede dejar sin efecto unilateralmente por medio de otra disposición *mortis causa* posterior, de modo que, cuando todos los otorgantes son al mismo tiempo causantes, se configura como un tipo negocial muy parecido al que, en otros ordenamientos, es el testamento mancomunado. Así, pues, esta asimilación pasa por el hecho de que los otorgantes instituyan heredero en las respectivas herencias, sea recíprocamente (heredamiento mutual preventivo)[7] o bien favoreciendo a un

[6] De hecho, el artículo 3 *b*) del Reglamento (UE) nº. 650/2012, anteriormente citado, considera que los acuerdos que llevan a los testadores a otorgar testamentos recíprocos son pactos sucesorios, ya que define estos últimos como «todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo».

[7] En el derecho catalán, desde la entrada en vigor de la Compilación, en el año 1960, la sucesión recíproca entre cónyuges (si dejamos de lado las adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia) se ha canalizado, sin ningún tipo de inconveniente, por la vía de los llamados heredamientos mutuales. Sin embargo, un sector de nuestra doctrina clásica representado, destacadamente, por CANCER (1670, cap. VII, nº. 136, 137, 143 y 150), había visto con recelo los pactos sucesorios entre cónyuges, entendiendo que eran un *pactum de succedendo* que no encontraba amparo en la *causa matrimonii*. En cambio, DE TRISTANY (1701, vol. III, dec. XCI, *per totum)* citando una sentencia del Regio Senado de 3 de mayo de 1698, mantenía la posición contraria, ya que consideraba válida la donación entre cónyuges hecha «mutuam sibi ad invicem fecerunt donationem omnium bonorum praesentium et futurorum, iurium et actionum in favorem ultimi morientis, cum reservatione 500 librarum ad testandum». A final del siglo XIX, también tenemos constancia del hecho de que el heredamiento mutual entre cónyuges se pactaba como cláusula complementaria del heredamiento preventivo a favor de los hijos. V., en este sentido, la «Nota de Redacción» de la revista *La Notaría* «Consultas sobre el Código civil», XXXII, nº. 1627 (1889, 10-6) p. 12838 y 12839) [reproducida en EGEA FERNÀNDEZ/MARSAL GUILLAMET, 1994, p. 320]. Pocos años después, DE BROCÀ (1918, p. 740 y 741), refiriéndose específicamente al heredamiento mutual preventivo, confirma que era

tercero (normalmente alguno de los hijos) ya sea directamente o como heredero sucesivo.

Para entender mejor la nueva configuración de los heredamientos, incluido naturalmente el preventivo, debe tenerse presente que actualmente los pactos sucesorios se caracterizan, sobre todo, porque, a diferencia de lo que habían sido históricamente, ya no se conciben como un acuerdo entre los padres que heredaban al hijo que se casaba y la familia de la mujer que constituía la dote, sino que se pueden otorgar al margen de la relación matrimonial. Es decir, estos pactos se configuran como un «convenir» la institución de heredero o una atribución particular con alguna de las personas referidas al art. 431-2 CCCat, sin que esta institución o atribución, necesariamente, deba tener ninguna vinculación con el matrimonio. Se puede afirmar, por lo tanto, que los pactos sucesorios se acercan bastante al esquema típico de los negocios gratuitos[8], en los que una de las partes es quien dispone y la otra el favorecido, aunque, como acabamos de ver, se puede pactar también que el favorecido sea un tercero.

En cualquier caso, no podemos perder de vista que, incluso en el supuesto de que el pacto tan solo se refiera a la sucesión de uno de los otorgantes, el elemento configurador sigue siendo el acuerdo de voluntades[9], lo cual presupone que, sean causantes o no, todos ellos deben tener un interés en la ordenación del contrato sucesorio. Lógicamente, este interés siempre está presente cuando uno es beneficiario de la sucesión ordenada por el otro otorgante y, también, cuando se hacen disposiciones recíprocas (a favor del que sobreviva) o a favor de un tercero al que instituyen heredero de forma correspectiva[10].

Por su parte, debe tenerse en cuenta que el testamento mancomunado, definido en los términos que hemos utilizado al principio de esta exposición, no es solo un instrumento sucesorio que posibilita la formulación de una pluralidad de voluntades testamentarias en un mismo acto de

---

una institución relativamente nueva que se consignaba en los capítulos matrimoniales previendo que, a la muerte de que cualquiera de los cónyuges, le heredaría el sobreviviente, el cual, si tuviera hijos, debería disponer de los bienes adquiridos de esta manera a favor de ellos. Finalmente, en el año 1960, la Compilación diseñó un régimen jurídico de los heredamientos mutuales que se siguió circunscribiendo a los cónyuges y que prescindió de toda referencia a la posibilidad de otorgarlos con carácter preventivo, que como veremos, se recuperaría el año 1991 con el Código de sucesiones.

[8] Según el preámbulo, las partes pueden causalizarlos de manera diferente –en referencia, al parecer, a que se pueden pactar con causa onerosa–, pero entiendo que se trata de una onerosidad que tiene un sentido diferente del previsto en el art. 1274 CC, ya que en los pactos sucesorios no hay una relación prestación/contraprestación, sino que su causa –a pesar de las posibles cargas– sigue siendo la gratuidad.

[9] Cuando un otorgante dispone *mortis causa* de su patrimonio y el otro se limita a aceptar aquella institución, asumiendo o no alguna carga, el pacto sucesorio no deja de ser, por esta razón, *unilateral*. La unilateralidad se refiere aquí a la disposición, no a las partes que intervienen en el otorgamiento (desde esta perspectiva, el pacto, sin duda, es, como mínimo, bilateral). En este sentido, resulta ilustrativo, a pesar de referirse al derecho alemán, el análisis que hace FLUME, Traducción de la 4ª edición (1992) de MIQUEL GONZÁLEZ y GÓMEZ CALLE (1999, p. 175), donde afirma que, a pesar de la vinculación contractual, la disposición por causa de muerte adoptada en contrato sucesorio es materialmente un negocio jurídico unilateral; lo mismo sostiene HESS (2002, p. 218 y 223).

[10] Obviamente, el interés también se justifica, por ejemplo, por el hecho que los otorgantes compartan el objetivo de alcanzar la finalidad que determina el pacto, como garantizar la continuidad en la sucesión de la empresa familiar, la transmisión indivisa de un establecimiento profesional o la fijación, con carácter irrevocable, de los sucesores de los cónyuges, garantizando de esta manera la posición de los hijos en caso de crisis matrimonial o de extinción de la pareja estable.

otorgamiento, sino que permite, al mismo tiempo, tratar unitariamente las disposiciones de ambos otorgantes. De aquí se deriva que lo más frecuente será −donde se admita este testamento− que las disposiciones sucesorias de cada testador estén interrelacionadas.

Estos testamentos, como veremos más adelante, habían sido admitidos en el *ius commune* e incorporados a la práctica testamentaria catalana. No fue hasta principios del siglo XIX, en pleno proceso codificador, que, por influencia del Código civil francés (art. 968), se generó una opinión abiertamente contraria a admitirlos y que acabaría desterrándolos, casi de forma definitiva, de la práctica consuetudinaria[11] en la que, hasta entonces, habían disfrutado de un cierto prestigio. Al respecto, de momento, basta recordar que el artículo 557 del proyecto de Código civil de GARCIA GOYENA de 1851 incorporó la prohibición del testamento mancomunado, obviando que el derecho castellano lo había estado admitiendo a través de la costumbre. La prohibición del proyecto isabelino se fundamentaba en las razones ya conocidas que he expuesto al inicio, sobre todo en el hecho de que, una vez otorgado el testamento, no estaba claro si uno de los cónyuges lo podía revocar en vida del otro sin que este llegara a enterarse, ni tampoco si lo podía hacer una vez que aquel hubiera muerto. En efecto, en el trasfondo de la discusión sobre la admisión de este testamento siempre subyace el hecho de que la revocación unilateral no comunicada al otro otorgante frustra la expectativa de este, ya que le impide decidir qué debe hacer con su disposición sucesoria.

Es así como en el año 1889 se llega al referido artículo 669 del Código civil español que, transcribiendo, de forma casi literal, el mencionado artículo 557 del Proyecto, prohibió testar mancomunadamente o en un mismo instrumento; prohibición que, según ya he avanzado, por un cierto mimetismo, se extendió al derecho catalán donde, formalmente, todavía sigue vigente. En este sentido, aunque algún autor, basándose en el carácter completo y autosuficiente de nuestro ordenamiento sucesorio, haya argumentado que, como este tipo testamentario no está expresamente prohibido, es posible su otorgamiento[12], se puede considerar pacífica la opinión que sostiene que no cabe en él.

Cabe decir, para acabar esta parte introductoria, que, años atrás, el legislador español reconoció, aunque limitadamente en el tiempo, la utilidad que el testamento mancomunado podía tener como instrumento para planificar la transmisión de la riqueza en el seno de la empresa familiar. Es en este sentido que la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del estatuto de la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes, estableció que, en este ámbito de la actividad económica, no se aplicaba la prohibición del artículo 669 CC. Los efectos, sin embargo, no fueron los deseados, de modo que la falta de efectividad práctica de esta previsión normativa llevaría, catorce años después, a su derogación por medio de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las

[11] La doctrina española, siguiendo GUTIÉRREZ (1871, p. 171), mayoritariamente, sitúa los orígenes del testamento mancomunado en la práctica consuetudinaria, descartando que pueda encontrar sus precedentes en el libro 3, título 6 de la Ley 9 del Fuero Real. V., por todos, LETE DEL RÍO/REQUEJO ISIDORO, 1997, p. 1020). Otros, como GARCÍA-GRANERO (1998, p. 539-541) han sostenido que, con evidencia contrastada, el mencionado fragmento del Fuero Real procede del *Liber Iudiciorum*, 4, 2, 18, lo cual confirmaría que, efectivamente, se refiere a una disposición *mortis causa* entre cónyuges.

[12] GARRIDO MELERO (1997, p. 488).

explotaciones agrarias[13]. A pesar de todo, últimamente, un sector de la doctrina española[14] se ha mostrado claramente favorable a eliminar, con carácter general, la prohibición del artículo 669 CC sobre la base, por un lado, de que los antecedentes históricos así lo avalan y, por otro, que no hay trabas de constitucionalidad que lo impidan, ya que el carácter personalísimo del testamento y todavía menos el unipersonal no forman parte del derecho constitucional a la herencia.

2. *Los testamentos pluripersonales en la tradición jurídica catalana*

La doctrina especializada descarta que el derecho romano −del que, en buena medida, el derecho civil catalán es tributario− hubiera admitido esta práctica testamentaria, ya que concebía el testamento como un acto esencialmente unipersonal y solemne; sin embargo, se ha hecho notar también que había alguna figura que dejaba entrever una cierta forma de testamento conjunto[15].

Los autores del *ius commune*, en cambio, adoptaron una posición favorable al testamento conjunto, tratando siempre de diferenciarlo de los pactos sucesorios que, por el contrario, no se admitían. Argumentaban que el hecho de que interviniera una pluralidad de causantes y que la ordenación de las disposiciones soliera ir precedida de una especie de negociaciones no tenía por qué llevar a la identificación de ambas figuras. Así lo encontramos expresado desde los posglosadores o primeros comentaristas hasta tratadistas muy posteriores. En esta línea, BARTOLO DE SAXOFERRATO (1313-1357), el jurista más insigne de la escuela de los comentaristas, admitía que dos personas o más pudieran testar en un mismo documento e instituirse recíprocamente herederas, siempre, eso sí, que el testamento no hubiera sido precedido de ningún pacto vinculante, porque, entonces, la institución mutua no sería válida[16]. Lo argumentaba, por una parte, sobre la base de que, en los testamentos mancomunados, los cotestadores no están unidos por ningún vínculo contractual y, de la otra, que las diferentes declaraciones de voluntad que concurren, por mucho que estén interrelacionadas, se pueden dejar sin efecto unilateralmente. Dicho en otras palabras, consideraba que, con las especificidades que les son propias, los testamentos mancomunados no dejaban de ser un verdadero testamento.

---

[13] El preámbulo justifica este cambio de criterio diciendo que «Si bien los objetivos de la citada Ley siguen siendo válidos, en gran medida, los instrumentos aplicados en su consecución no se han mostrado eficaces».

[14] Por todos, GARCÍA VICENTE (2006, p. 293).

[15] Concretamente, se suele citar un rescripto, publicado bajo el cuarto y tercero mandatos, respectivamente, de DIOCLECIANO i MAXIMIANO, en el año 290 (C. 2, 3, 19), que admitía la validez del acto de institución mutua de heredero realizado por dos hermanos militares. Por otra parte, se cita también la Novela 21,1 del emperador VALENTINIANO III, año 446, según la cual, desde una perspectiva formal, no había razón para dudar de la validez del testamento, aunque hubiera sido otorgado por dos testadores en un mismo documento («quamvis in unius chartae volumine»). Hay que recordar también que JUSTINIANO no incluyó esta Novela en el *Corpus Iuris*, sino que fue recibida en Occidente por medio de la Lex Romana Visigothorum (conocida por lo común como Breviario de Alarico II [año 506]). Ciertamente, tampoco han faltado autores que, como Biondo BIONDI, *Sucesión testamentaria y donación*. 2ª edi., traducido del italiano por FAIRÉN (1960, p. 31), señalan que, en estos casos, los textos romanos propiamente se referían en una especie de pacto sucesorio.

[16] BARTOLI A SAXOFERRATO (1589, fol. 172, n. 3.)

En este mismo sentido, OLDRADUS DE PONTE (†1335)[17] había afirmado que, aunque los cónyuges hubieran otorgado testamento en un único documento, en realidad había dos testadores, de manera parecida a cuando el padre sustituía el hijo impúber. A partir de aquí, reitera el carácter esencialmente revocable de este tipo testamentario, y específica, además, que el cónyuge sobreviviente también podía modificar su disposición.

Nuestros clásicos, receptores directos de la doctrina del *ius commune*, incorporaron el mismo criterio, testimoniando así la admisibilidad de esta forma testamentaria en el derecho catalán histórico. Así, podemos citar, en primer lugar, al gerundense Tomàs MIERES (1400-1474), el cual, después de afirmar que se podían otorgar dos testamentos en un solo documento, añade que los testigos podían ser los mismos[18]. Posteriormente, Jaume CANCER (1559-1631),[19] al rechazar la validez de los *pacta de succedendo*, es decir, del pacto mediante el cual, fuera de capítulos (recordamos que en Cataluña se admitían los heredamientos o pactos sucesorios capitulares), alguien promete a otro, incluso con carácter recíproco, que sus bienes pasarán al sobreviviente una vez haya muerto el promitente, admite en cambio el testamento conjunto porque es revocable. Considera que lo determinante es que exista la posibilidad de revocar, de forma que, habiendo testado ambos cónyuges en un mismo documento (por ejemplo, instituyéndose mutuamente herederos con sustitución a favor de los hijos), muerto uno de ellos, el sobreviviente puede cambiar su voluntad testamentaria[20]. Una vez más, se constata que el hecho de que el testamento conjunto o mancomunado se pueda revocar en cualquier momento se convierte en clave para la admisión de esta figura sucesoria. De la misma opinión era Joan Pere FONTANELLA (1575-1649),[21] que destaca, nuevamente, que el sobreviviente es libre de revocarlo.

En la misma línea, Acaci Antoni DE RIPOLL (1578-1658), respondiendo a una consulta que le habían hecho sobre la validez de un testamento otorgado conjuntamente por unos cónyuges que se instituían mutuamente herederos, opina que para que el testamento sea válido es necesario que lo hayan suscrito ambos otorgantes. Es decir, si solo ha sido escrito por un testador, la institución hecha en favor de este no valdrá, a menos que haya sido suscrita por el causante, porque solo en este caso la institución queda fuera de cualquier sospecha[22].

Aunque, como acabamos de ver, la doctrina clásica catalana no puso obstáculos a la admisibilidad de los testamentos pluripersonales, sorprende que no hubieran sido objeto de estudio o que ni siquiera aparezcan mencionados por los tratadistas prácticos catalanes, que a lo

---

[17] *Consilia et quaestiones.* Consilia 174, Roma 1742. Münchener DigitalisierungsZentrum (Bayerische Staats Bibliothek).

[18] MIERES (1621): «[I]tem nota quod duo testamenta possunt fieri in una charta et praesentibus eisdem testibus: vide *de vulg. et pu. l. patris et filii*».

[19] CANCER (1670).

[20] PEREGRINUS (1600).

[21] FONTANELLA (1719).

[22] RIPOLL (1630).

largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, siguiendo el esquema de la obra de ROLADINO[23] (1215-1300), se ocuparon del llamado 'Arte de la notaría', ya que es en sede notarial donde, en principio, sería lógico esperar que se hubiera dedicado más atención. Me refiero, por ejemplo, a las obras de los notarios catalanes Hieroni GALI (SIGLO XVII)[24], Josep COMES (1655-1729)[25], Vicenç GIBERT (SIGLO XVIII)[26] y Fèlix Maria FALGUERA (1811-1897)[27], ninguno de los cuales, como decía, hace referencia a ello. Esta omisión, seguramente, se justifica por el hecho de que, desde el punto de vista meramente escriturario –que suele ser la materia de la que estas obras se ocupan principalmente–, no había ninguna especificidad que diferenciara el testamento mancomunado del ordinario, ya que se presentaba como una simple confluencia de dos testadores en el mismo documento.

En cualquier caso, lo cierto es que, incluso bien entrado el siglo XIX, buena parte de la doctrina jurídica catalana siguió dando testimonio de esta práctica testamentaria en Cataluña. Así, por ejemplo, ELIAS (1817-1881) y DE FERRATER (1812-1877) sostenían que la ley tan solo prohibía los pactos sucesorios [hay que entender que se refería a los no capitulares], de modo que el testamento otorgado de forma mancomunada era válido[28]. Igualmente, Manuel DE BOFARULL I PALAU (1851-1929) distinguía[29] entre los "*testamenta recíproca*", entendidos como aquellos en que dos personas se instituyen mutuamente herederas en un mismo documento, y los "*testamenta correspectiva*", es decir, los otorgados también en un único documento, en el que cada uno de los testadores pone como condición de validez y eficacia que el otro no modifique sus disposiciones. Añadía, también, que bastaba que las formalidades ordinarias se observaran una sola vez, exceptuando, dice, la de rogar a los testigos, que debía hacer por separado cada testador.

Por otra parte, DE BROCÀ (1850-1918) y AMELL (1848-1855) [30], después de dejar constancia nuevamente del hecho de que el testamento mancomunado lo solían otorgar los cónyuges, sitúan sus antecedentes en el derecho romano, que, como hemos visto, lo había admitido de forma solo excepcional. Respecto al régimen jurídico, afirman que no es necesario que se repitan las solemnidades para cada testador, salvo la rogación de testigos, que, coincidiendo con lo que también sostenía BOFARULL, debía hacerse separadamente para cada uno de ellos.

---

[23] RONALDINI RUDOLPHINI BONONIENSIS (1565).

[24] GALÍ Y RAMÓN (1682). Se da la circunstancia que solo se publicó el primer volumen, en el que únicamente se incluye la primera parte del Arte de Notaría, los contratos, y falta todo lo que se refiere a las últimas voluntades y a los juicios, lo que podría explicar que no se haga alusión a los testamentos mancomunados.

[25] COMES (1704 [vol.I] 1706 [vol.II]).

[26] GILBERT (1772).

[27] GILBERT (1875).

[28] ELIAS (1864, p. 302). Unos años después, el mismo ELIAS (1877, p. 461), defiende también la validez del testamento mancomunado que, entonces, según afirma, se solía circunscribir a los cónyuges (art. 5116).

[29] DE BOFARUL Y DE PALAU (1878), cuadro 43.

[30] DE BROCÁ Y MONTAGUT / AMELL Y LLOPIS (1886, p. 316).

De la anterior exposición, se puede concluir que nuestra doctrina histórica, fiel seguidora del *ius commune*, admitió el testamento mancomunado con cierta prevención, ya que insistía en definirlo como la suma de dos testamentos independientes, sin más punto de conexión que el meramente accidental y formal de figurar en un único documento. Esto es lo que explica, como ha señalado GARCIA-GRANERO[31], que, obviando que se pudiesen manifestar voluntades interrelacionadas, se le aplicara el régimen del testamento unipersonal; singularmente la libre revocabilidad unilateral, tanto en vida de los cónyuges, como, muerto uno de ellos, por el sobreviviente.

Fue a finales del siglo XIX cuando apareció un movimiento directamente contrario a la validez de estos testamentos que encabezó una de las corporaciones del ámbito jurídico más relevantes del país. Me refiero al Colegio de Notarios de Barcelona, que convirtió el silencio que antes hemos visto que mantenían los tratados de notaría en una posición abiertamente contraria a la admisibilidad del testamento mancomunado. Concretamente, en el año 1883, la revista *La Notaría*, órgano oficial de los notarios en Cataluña, publicaba un breve artículo de Manuel REDONDO REINOSO titulado «Testamentos mutuos»[32] −que inicialmente había visto la luz en la *Gaceta de los Colegios Notariales*−, donde defendía que eran nulos. También, poco antes de que se promulgara el Código civil español y, por lo tanto, que entrara en vigor la prohibición del artículo 669 CC, la misma revista *La Notaría* había publicado una 'Nota de Redacción',[33] donde constataba que «[...] con notable sorpresa hemos visto introducirse y propagarse de pocos años a esta parte en Cataluña los testamentos mancomunados» y aconsejaba a los notarios que no los autorizaran, afirmando que «[...] creemos hacernos intérpretes de la opinión de la Junta Directiva aconsejando a los notarios que rechacen esta clase de testamentos». Paradójicamente, eso no impidió que, poco después, el mismo Colegio de Notarios los admitiera para la comarca de Tortosa, vista la especificidad del régimen económico matrimonial (l'*agermanament*) de aquel territorio[34].

Tan pronto como entró en vigor el artículo 669 CC, la misma corporación notarial consideró que este precepto regía también para Cataluña y, por esta razón, aprobó la Circular de 20 de diciembre de 1889, donde se decía que la Junta había acordado que, respecto de los testamentos mancomunados: «[...] se atenderán al Código Civil que los prohíbe, pues no existe disposición alguna que los permita en el derecho catalán, en el romano, ni en el canónico; antes bien están en oposición con los principios del romano y no pueden tampoco apoyarse en el derecho consuetudinario, porque no han sido admitidos por costumbre general de Cataluña, sino introducidos por una práctica tolerada por falta de impugnación en algunas comarcas»[35]. En

[31] GARCÍA-GRANERO (1998, p. 708).

[32] *La Notaría,* XXVI, núm. 1310 (1883-XXVI), pp. 10247-10251.

[33] *La Notaría,* XIX, núm. 1484 (1886, 13-IX), p. 11670.

[34] MARSAL GUILLAMET (2000, p. 168) reproduce el escrito publicado en *La Notaría XXXII,* núm. 1498 (1886, 20-XII) pp. 11782-11784, que da respuesta a una pregunta dirigida por un notario de Tortosa, afirmando «que la forma de testar mancomunada entre los esposos está expresamente sancionada en esta comarca por la *Cost. XX, Rub. IV. De ordinació de testaments libro VI de las costumbres escritas de Tortosa*, y entendemos que no puede el Código prescindir de ella, atendido el sistema de asociamiento universal entre los esposos en el mismo Código establecido y que no es igual al que se conoce en el resto de Cataluña».

resumidas cuentas, el posicionamiento de la corporación notarial en contra de este tipo testamentario fue más que notable, ya que la redacción de *La Notaría* volvería a abordar esta problemática, ahora de forma mucho más expeditiva, calificando su práctica de costumbre contra ley.[36]

3. Las propuestas de regulación del testamento mancomunado en el derecho catalán

A pesar del seguimiento que la prohibición del artículo 669 CC encontró en la práctica notarial catalana, un destacado sector doctrinal y también influyentes instituciones jurídicas del país siguieron posicionándose a favor del testamento mancomunado formulando, incluso, propuestas articuladas de regulación.

En este sentido me referiré, en primer lugar, a la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, que en el año 1899 fijó unas reglas básicas para la elaboración de un apéndice de derecho catalán al Código civil español, donde se admitía abiertamente. Hay que reseñar, además, que no se trataba de una simple muestra de fidelidad a la tradición histórica, sino que, en una visión muy pragmática, lo justificaba por el hecho de que posibilitaba que los cónyuges pudieran considerar las respectivas herencias como una unidad, facilitando la distribución entre los hijos[37].

En la misma línea, el artículo 454 del anteproyecto de apéndice que en el año 1903 redactaron ROMANÍ I PUIGDENGOLAS (1831-1912) y TRÍAS Y GIRÓ (1861-1914) incluía una regulación, aunque escasa, de este tipo testamentario, en la que, sin restringirlo a los cónyuges, destacaba también el carácter esencialmente revocable, tanto en vida como después de la muerte de uno de los otorgantes[38].

---

[35] La Circular, publicada en *La Notaría XXXII,* nº. 1665 (1889, 23-XII) p. 13065-13066, puede verse reproducida en, EGEA FERNÀNDEZ/MARSAL GUILLAMET (1994, p. 319-320).

[36] MARSAL GUILLAMET (2000, p. 169) es quien, nuevamente, nos da noticia de esta otra nota de la redacción (*La Notaría XXXIII* nº. 1663 (1890, 17-II) p. 13135.

[37] *Memoria formulada por la Comisión nombrada en sesión de 31 de mayo de 1899, compuesta por los señores Magín Pla y Soler, D. Felipe Bertrán de Amat, D. Guillermo Ma. de Brocá, D. José Pella y Forgas, D. José Estanyol y Colom, D. Guillermo A. Tell y Lafont y D. Antonio Ma. Borrell y Soler acerca de las Instituciones Jurídicas de Cataluña que conviene conservar en el Apéndice al Código Civil y aprobada por la Academia en sesión de 28 de agosto de 1899*, Barcelona, 1899, p. 40.

[38] *Anteproyecto de Apéndice del Código Civil para el Principado de Cataluña que presenta la Comisión Especial constituida con arreglo al Real Decreto de 24 de abril de 1899. D. Francisco ROMANÍ Y PUIGDENGOLAS, Presidente de dicha Comisión, y D. Juan de Dios TRÍAS Y GIRÓ, vocal de la misma, representante del Colegio de Abogados de Gerona. Precedido de un Prólogo del primero de dichos señores*. Edición publicada con una introducción por la *Revista Jurídica de Cataluña* (de Joan Martí i Miralles), Barcelona 1904. El mencionado precepto decía: «Será lícito que dos o más personas testen en un mismo acto. Esta forma de testar no impedirá que cualquiera de los otorgantes pueda alterar su testamento en vida de los demás o fallecidos estos. La parte del testamento que se refiere a las disposiciones de los demás que hubiesen testado mancomunadamente, sólo podrá variarse con su consentimiento».

Todas estas iniciativas prelegislativas de carácter privado, que como es sabido no fructificaron, estaban en sintonía con la opinión de buena parte de los civilistas catalanes de principios del siglo XX, que se siguieron manifestando en contra de la aplicación del mencionado artículo 669 CC en Cataluña. Aquí me limitaré a citar los dos más destacados. Por un lado, el notario de Reus y profesor auxiliar de la Universidad de Barcelona, CORBELLA (1851-1923), el cual afirma que el testamento mancomunado era una institución del derecho consuetudinario de Cataluña que solían utilizar los cónyuges[39]. Consideraba (como, de hecho, también lo había ido entendiendo la doctrina clásica) que, visto su carácter de acto de última voluntad, constituía un negocio jurídico esencialmente revocable sin el consentimiento del otro, en aquello que afectara a cada uno de los testadores. Dicho en otras palabras, advertía que se trataba de dos testamentos diferentes hechos, sin embargo, en un solo acto. Por otro, PELLA I FORGAS (1852-1918) también nos ha dejado constancia de la utilidad de los testamentos conjuntos con disposiciones correspectivas o recíprocas y del hecho de que entonces se otorgaban en Cataluña[40].

En relación con aquella misma época, es decir, inmediatamente después de la entrada en vigor del Código civil español, también encontramos algún referente jurisprudencial de la vivencia práctica de este testamento en Cataluña. Así, por ejemplo, la *Revista Jurídica de Cataluña*[41] se hizo eco de una sentencia de la Audiencia territorial de Barcelona, de la que no consta la fecha, referida a la validez de un testamento mancomunado otorgado en el año 1880, en el que el tribunal alude a su raíz consuetudinaria y constata que, con más o menos frecuencia, se habían estado otorgando válida y eficazmente en Cataluña. Igualmente, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 8 de mayo de 1901, trató también de un testamento mancomunado otorgado en Cataluña, aunque no tuvo que pronunciarse sobre el fondo, ya que las partes no cuestionaban la validez, sino que las discrepancias se centraban en la sustitución hereditaria que se contenía.

En la primera mitad del siglo XX, BORRELL Y SOLER (1864-1956), distinguiendo entre el testamento meramente mancomunado, el recíproco y el correspectivo, concluye que el primero era plenamente admisible, ya que no había sido prohibido por ninguna ley, y añade que, a pesar de la conocida posición del Colegio de Notarios, el artículo 669 CC no era aplicable en Cataluña. Respecto a los correspectivos y recíprocos, a pesar de admitir que tienen una cierta proximidad con los pactos sucesorios (de los que llega a afirmar que son una primera manifestación), concluye que, en Cataluña, donde se admiten los heredamientos a favor de los hijos y los mutuales entre cónyuges, en pura lógica se deberían admitir también estos testamentos[42].

---

[39] CORBELLA (1906, p. 738).

[40] PELLA (1918, p. 115).

[41] Núm. 6 (1900), p. 85 a 91 y que recoge también MARSAL GUILLAMET, (2000, p. 169, nota 338).

[42] BORELL I SOLER (1944, pp. 49 i 50). Por otra parte, al tratar del heredamiento mutual (*op. cit.* IV, p. 308 y 309), lo llega a comparar con una especie de pacto de sobrevivencia ampliado, que «garantiza que la fortuna de un cónyuge pasará, a la muerte del testador, en poder del otro; y como esta mancomunidad se establece no solo como consecuencia del afecto personal mutuo entre ellos [*los cónyuges*], sino que cada cual tiene en cuenta la reciprocidad estable y segura que no puede quebrantarse sino por ambos a la vez, se evita la mala fe y el engaño de una revocación a deshora y subrepticiamente por uno de los testadores».

Ninguna de las anteriores propuestas cuajó normativamente. Es más, la omisión que, años después, la Compilación de 1960 hizo del testamento mancomunado, unida al carácter supletorio que la disposición final segunda atribuía al Código civil español, en lo que no previera la Compilación, determinó, ya sin discusión, que el régimen aplicable a Cataluña fuera el que establecía el artículo 669 CC, es decir, la prohibición absoluta.

No será hasta treinta años después que no volvamos a encontrar una propuesta de incorporación de este testamento al ordenamiento civil catalán, ahora sí de carácter oficial. Me refiero al anteproyecto de ley del Código de sucesiones, elaborado en el año 1990 por el Departamento de Justicia, que lo limitaba a los cónyuges y a la modalidad notarial abierta. Concretamente, la exposición de motivos que acompañaba el documento de trabajo que contenía el anteproyecto lo justificaba, por una parte, por los antecedentes históricos, entendiendo que era un testamento arraigado en Cataluña hasta que entró en vigor la prohibición del art. 669 CC y, de otra, que se trataba de una necesidad sentida socialmente.

En esta parte, el anteproyecto iniciaba la regulación del testamento mancomunado con un precepto que podemos calificar de reactivo, con el que se quería dejar claro que se admitía, y, acto seguido, preveía que se pudiera revocar por decisión conjunta de los testadores. Establecía, por otra parte, que las disposiciones correspectivas (es decir, las que los testadores se hacen recíprocamente y las que se vinculan a las que hace el otro) eran revocables unilateralmente, siempre y cuando la revocación se hiciera en testamento abierto y se notificara al otro consorte en el plazo de ocho días hábiles. Finalmente, determinaba que si, muerto uno de los cónyuges, el sobreviviente aceptaba las atribuciones que el premuerto había ordenado a favor suyo, ya no podía modificar o revocar las disposiciones correspectivas que todavía estuvieran vigentes[43].

La propuesta del anteproyecto no tuvo éxito en este punto y, consiguientemente, no pasó al Proyecto de ley de Código de sucesiones que el Parlamento de Cataluña aprobaría como ley en el año 1991.

El último intento de inclusión del testamento mancomunado en nuestro ordenamiento, que, por otra parte, ni siquiera pasaría al proyecto, lo encontramos, cinco años después, en el anteproyecto del libro IV del Código civil de Cataluña (2006), relativo a las sucesiones[44]. Se establecía que los testadores debían ser mayores de edad y que las disposiciones no podían tener carácter vinculante o correspectivo (de lo contrario, el art. 421-17 se remitía a la regulación de los pactos sucesorios). Además, contenía la cautela de la notificación al otro testador y la publicación de edictos, si aquella no hubiera sido posible (art. 421-18 CCCat). En mi opinión, dicho sea de paso, estas previsiones no tenían mucha razón de ser en un testamento conjunto que solo posibilitaba que cada testador, de forma no interrelacionada, dispusiera de su herencia.

[43] El texto completo se puede consultar en MARSAL GUILLAMET (2000, p. 166).

[44] Recogido en el volumen editado del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña *Projectes de llei del Codi civil de Catalunya.* Barcelona 2006, p. 278 y 279.

4. La funcionalidad del heredamiento preventivo como testamento mancomunado. Similitudes y diferencias entre ambos

4.1. Consideraciones generales

Las instituciones preventivas constituían, históricamente, unas cláusulas capitulares vinculadas a la facultad de elegir al heredero que el padre solía estipular como forma de completar un heredamiento prelativo, es decir, el que establecía la preferencia de los hijos del matrimonio en consideración al que se había otorgado el heredamiento sobre los de un hipotético matrimonio posterior[45]. Con esta técnica se pretendía facilitar que el padre heredante, después de ver cuáles eran las cualidades de cada hijo y su dedicación a "la casa", pudiera designar testamentariamente al que considerara más apto para garantizar la continuidad; y para el caso que no lo hiciera, preveía quien le tenía que suceder.

Fue a fines del siglo XIX que los pactos preventivos alcanzaron una cierta autonomía en el sentido que pasaron a ser concebidos, directamente, como instrumentos ordenadores de la sucesión, con los que se pretendía, simplemente, evitar que, por la razón que fuera, entrara en juego la sucesión intestada[46]. Siguiendo esta corriente, la regulación que hizo el artículo 89 de la Compilación de 1960 (que reprodujo después el artículo 93 CS, añadiendo a los hijos nacidos y a los adoptados) tampoco se ciñó a esos precedentes históricos, siguió tipificando el heredamiento preventivo como pacto sucesorio autónomo.

En la misma línea, el vigente artículo 431-21 CCCat extiende todavía más su alcance, ya que no lo circunscribe a los hijos o a la institución recíproca entre cónyuges, sino que admite que el heredero pueda ser cualquier persona. Todo ello, no hace falta decirlo, siempre y cuando los otorgantes pertenezcan al círculo familiar que enumera el artículo 431-2 CCCat, al que aludiré más adelante.

Por otra parte, la voluntad del legislador catalán de generalizar las estipulaciones preventivas ha

[45] La fórmula capitular que se utilizaba con más frecuencia y que reproduce DE TRISTANY (1688, pp. 368 y ss.), era: «Hereta y dóna per causa de donació pura, perfecta, simple y irrevocable... al fill o fills mascles del present matrimoni... aquell, que entre vius o en sa darrera voluntat elegirà i en cas que no elegís vol succehesca lo primer fill mascle del present matrimoni». Así lo vemos reflejado también en otra cláusula típica recogida en unos capítulos matrimoniales otorgados el 6 de octubre de 1625, que, en este caso, transcribe MARMER, «Pro Maria Vila et Font... contra Joannem Petrum Font, agricolam parochiae de Vidrà». (s.d.) [finales s.XVII] que es del tenor siguiente: «[...] fa donació y heretament de tots sos bens, y drets, mobles, e immobles, presents y esdevenidors al fill o filla del present matrimoni procreadors, à d'aquell, és a saber, o aquella, que per ell dit Jaume Font serà anomenat hereu seu universal en son últim testament, ab los pactes y condicions seguents: ço és, que si era cas que dita Catarina muller sua li premorís y ell se tornara a casar, y del present matrimoni no y havia sino filla, o fillas, y del segon matrimoni tenia fill, que tinga llibertat, conforme ara se reserva de nomenar, y fer hereu seu, filla del present matrimoni, o fill del segon matrimoni, conforme ben vist li sera, aquell és a saber, o aquella que a dit Jaume Font aparrà més apte, y sufficient per regir y governar sos béns... y en tot cas si moris intestat, ara per a las horas, anomena y fa hereu seu universal, lo fill major de dins del present matrimoni procreador, y si no tindra fill, la filla major de dias, y los altres sian dotats conforme lo poder de dits béns...».

[46] Véase, en este sentido, PLANAS I CASALS (1925, p. 328).

llevado a admitir que también los pactos de atribución particular puedan tener este carácter (art. 431-29.2 CCCat), lo que no acaba de encajar con la función que tradicionalmente han desarrollado ese tipo de estipulaciones en nuestro derecho: evitar los efectos que derivan del hecho de que el causante muera sin haber otorgado testamento[47]. Por lo demás, lo cierto es que, como ya he avanzado, con la entrada en vigor del libro IV del Código civil de Cataluña se ha profundizado en la desnaturalización del significado estricto que los heredamientos preventivos habían tenido hasta entonces, ya que, pura y simplemente, han pasado a ser sinónimo de pacto sucesorio revocable, de modo que, como dice el preámbulo, las estipulaciones preventivas se hacen «indistinguibles de las testamentarias»[48]. Precisamente, ha sido la innegable proximidad entre testamento y heredamiento preventivo y, consiguientemente, la necesidad de mantener un perfil propio para uno y otro, la que ha llevado a establecer, por un lado, que el carácter preventivo no se presuma nunca, sino que debe estipularse expresamente y, por otro, que ha de quedar claro que el heredamiento es revocable (art. 431-21.3 CCCat).

Así pues, a pesar de la generalidad de los términos con los que está redactado el apartado 1 del referido artículo 431-21 CCCat, es lógico pensar que, en la práctica, no abundarán los heredamientos preventivos unilaterales, ya que lo más probable es que, para obtener el mismo resultado, los interesados opten por la fórmula más sencilla de otorgar testamento. En cambio, vista precisamente la prohibición de los testamentos mancomunados, los heredamientos preventivos deberían convertirse en el instrumento idóneo para canalizar las instituciones de heredero que, con carácter revocable y en un mismo acto, ambos otorgantes −normalmente los cónyuges− quieran hacerse recíprocamente o aquellas que, de forma interrelacionada, instituyan a un hijo o a otra persona.

4.2. Modalidades de heredamiento preventivo con pluralidad de causantes

El libro cuarto del Código civil de Cataluña posibilita que cualquier tipo de heredamiento se pueda pactar con carácter preventivo[49], dando forma, de esta manera, a una regulación que, como ya ha quedado dicho, se aleja bastante de sus orígenes históricos. Es decir, el nuevo alcance que el Código ha dado al heredamiento preventivo permite, como hemos visto, configurarlo con entidad propia, de manera que, con un diseño adecuado, debería poder ocupar el lugar del testamento mancomunado.

---

[47] Hay que recordar que, en el ordenamiento sucesorio catalán, el calificativo *preventivo* tradicionalmente ha indicado que la institución así formulada tiene como finalidad evitar la sucesión intestada (cf., por ejemplo, el art. 426-59 CCCat para la sustitución preventiva de residuo), de manera que, a menos que lo que se quiera sea, simplemente, establecer la revocabilidad, no parece apropiado trasladarlo a los pactos sucesorios de atribución particular, ya que no evitan la sucesión legal.

[48] Como hemos visto en la nota 42, la asociación entre el heredamiento mutual preventivo y el testamento mancomunado, en la doctrina, ya lo había hecho BORRELL I SOLER y, tiempo después, ROCA TRÍAS (1974, p. 151-176).

[49] No obstante, es lógico pensar que no se pacte en los heredamientos cumulativos, dado que no es previsible que alguien que se reserva la facultad de revocar la institución de heredero al mismo tiempo se desprenda de todos los bienes presentes.

Obviamente, para que se pueda hablar de esta asimilación de funciones hace falta que los otorgantes sean al mismo tiempo causantes, es decir, que las disposiciones sucesorias ordenen las herencias respectivas. Es en este sentido que puede decirse que los heredamientos preventivos son verdaderos negocios de última voluntad, ya que, como en los testamentos, el causante puede dejar sin efecto, en cualquier momento, dicha disposición sucesoria otorgando un testamento posterior, que deberá ser notarial y abierto, u otro pacto sucesorio (art. 431-21.1 CCCat).

Los pactos sucesorios preventivos relativos a la sucesión de diversas personas se pueden clasificar en dos categorías, que, como veremos en seguida, coinciden con las que también encontramos en los testamentos mancomunados. Ambas tienen en común el carácter interdependiente de todas las disposiciones que contienen, con la condición que, en última instancia y a diferencia del testamento, en el heredamiento la interrelación siempre tiene una base contractual. Dicho de otra forma, en el derecho catalán, las disposiciones *mortis causa* que no sean meramente unipersonales quedan impregnadas del carácter contractual propio de los pactos sucesorios[50]. Eso significa que, a menos que los otorgantes acuerden que se mantenga la vigencia de alguna estipulación con independencia de las otras, la regla es que las estipulaciones que integran los pactos sucesorios no gozan de la autonomía ni la independencia que en el testamento pueden tener la institución de heredero o los legados, sino que forman parte del acuerdo de voluntades que configura un único negocio jurídico. Así, a pesar de que tanto el artículo 431-11 CCCat como el artículo 431-13.4 CCCat, en sede de nulidad y de revocación, respectivamente, aluden específicamente a la posible existencia de disposiciones correspectivas, entiendo que todas las estipulaciones que integran el pacto sucesorio siempre tienen carácter interrelacionado, vista la tantas veces citada naturaleza convencional o acordada de la sucesión contractual.

Precisamente, el carácter esencialmente interrelacionado de las disposiciones que se incorporan en un pacto sucesorio excluye que pueda caber una tercera modalidad, que, también por mimetismo con el testamento mancomunado, se podría denominar heredamiento *meramente simultáneo*, es decir, el relativo a las disposiciones sucesorias que, de forma autónoma y sin vinculación con las otras del mismo pacto, pudieran hacer cada uno de los otorgantes. Partiendo de esta premisa, los podemos dividir en dos tipos:

A. Pactos sucesorios preventivos en beneficio mutuo (heredamientos mutuales preventivos)

El artículo 431-20 CCCat define el heredamiento mutual como aquel en el que los otorgantes se instituyen recíprocamente herederos, resultándolo ser el que sobreviva y sin que sea necesario que acepte la herencia o, para ser más precisos, sin que pueda renunciar a ella (art. 431-5.2 y 431-28.1 CCCat). Ahora bien, la doctrina[51] había considerado ilusorio pensar que, tal como inicialmente lo había diseñado la Compilación, pudiera haber cónyuges que pactaran este tipo de heredamiento; y ello, no solo por su carácter irrevocable, sino también por la limitación de las facultades dispositivas *inter vivos* que comportaba.

[50] Véase, en este sentido, JOU I MIRABENT (1994, p. 80).

[51] LÓPEZ BURNIOL (1994, p. 408).

El primero de estos obstáculos, la irrevocabilidad, fue eliminado en el año 1991 por el ya derogado Código de sucesiones, que admitió que el carácter preventivo (hasta entonces circunscrito, como hemos visto, a los heredamientos a favor de los hijos) se pudiera pactar también en los mutuales (entonces aun limitado a los cónyuges, art. 99 CS). En cambio, lo que no hizo –y que tampoco ha hecho el Código civil de Cataluña, a mi parecer con buen criterio– fue eliminar las limitaciones que la ley impone para disponer gratuitamente *inter vivos*. Efectivamente, sin distinguir entre si han sido pactados con carácter preventivo o no, el Código establece que el heredante, mientras viva, no puede realizar actos de disposición a título gratuito, sino es con consentimiento del otro otorgante, a menos que sea para satisfacer legítimas o para hacer liberalidades de uso. Esto se justifica, como veremos después, porque, a pesar de la incertidumbre sobre quién acabará siendo efectivamente heredero, al haberse instituido recíprocamente, los otorgantes son titulares, hasta que mueran, de esta expectativa, y no se puede dejar en manos de uno solo la efectividad, económicamente hablando, de la institución hereditaria. Si no fuera así, se posibilitaría que, disponiendo gratuitamente de los bienes, dicha institución, llegado el momento de la muerte, quedara materialmente vacía de contenido, manteniéndose la otra parte en la ignorancia de este hecho. Como he dicho, retomaré este tema más adelante (en el apdo. 4.7).

Aparte de la institución recíproca de heredero, el heredamiento mutual preventivo puede incorporar, según admite el artículo 431-20.2 CCCat, una sustitución fideicomisaria que grave los bienes heredados con la carga que, a la muerte del heredero, hagan tránsito[52] a otras personas designadas en el mismo heredamiento o a quien elija el sobreviviente, supuesto que se remite a los artículos 424-1 a 424-4 CCCat, que regulan la elección de heredero por fiduciario. En mi opinión, habría sido más apropiado que esta remisión se hubiera hecho en las normas relativas al fideicomiso de elección; que no lo haya hecho se explica, seguramente, porque se ha impuesto el hecho de que, en la práctica, el ámbito subjetivo de aplicación de los heredamientos mutuales seguirá siendo el de los cónyuges o las parejas estables y, a partir de aquí, que la elección deba recaer en los hijos o los descendientes. Asimismo, se puede pactar el destino que han de tener los bienes propios del causante sobreviviente, caso en el cual resultará que, muerto este, se abrirá la segunda sucesión y el heredero o herederos designados deberán aceptar la herencia.

B. Pactos sucesorios preventivos en beneficio de tercero

En esta modalidad de sucesión contractual, los otorgantes instituyen heredera, con carácter revocable, a una persona que no ha intervenido en el otorgamiento. Se trata de un tipo de pacto que más bien está pensado para que se estipule entre los consortes o convivientes en pareja estable que quieren instituir herederos a los hijos. De hecho, el propio preámbulo de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, parece partir de esta premisa, cuando, para ejemplarizarlo, se refiere, precisamente, al hecho de que «el padre y la madre pacten, entre ellos dos, que la herencia sea para uno o unos hijos determinados, aunque no tengan el consentimiento de estos». Obviamente, eso no excluye que

[52] La expresión «hacer tránsito» se utiliza, en el derecho sucesorio catalán, como sinónimo de que el efecto adquisitivo se produce directamente, sin necesidad de aceptación, como pasa, por ejemplo, en la sustitución fideicomisaria (art. 426-1, 426-23.2, 426-51 y 426-58 CCCat) o en los legados de naturaleza real (art. 427-22 CCCat).

los otorgantes puedan favorecer a cualquier otra persona, aunque no haya ninguna relación de parentesco o, incluso, que instituyan a una persona jurídica existente o que se haya ordenado crear en el mismo pacto sucesorio.

En cualquier caso, los terceros instituidos, al no ser otorgantes del pacto, deberán tener, como en el testamento, capacidad sucesoria en el momento de la muerte del causante. Es decir, a fin de que la institución de heredero llegue a ser eficaz, es necesario que el instituido haya nacido o al menos esté concebido al abrirse la sucesión, así como que sobreviva al causante (art. 431-3.2 CCCat). Respecto a las prohibiciones de suceder, rigen, en lo que permita la naturaleza paccionada de la sucesión, las mismas reglas, que, con carácter general, establece el artículo 412-5 CCCat.

4.3. Legitimación y capacidad

Respecto de las personas que pueden otorgar heredamiento preventivo, el Código civil de Cataluña establece los mismos requisitos de legitimación y de capacidad que para el resto de heredamientos, que, como veremos en seguida, no coinciden exactamente con los que se fijan para los testamentos.

Empezando por la legitimación, hay que señalar que mientras en el heredamiento los otorgantes (causantes o no) han de pertenecer al círculo familiar que establece el artículo 431-2 CCCat, en el testamento, en cambio, no rige esta limitación, aunque algunos de los ordenamientos que, en el derecho comparado, admiten el testamento mancomunado lo restringen a los cónyuges[53]. Así, se puede convenir heredamiento preventivo con el cónyuge o futuro cónyuge, con el conviviente en pareja estable, con los parientes –por consanguinidad o por afinidad– en línea directa (sin límite de grado) o en línea colateral, dentro del cuarto grado, y también con los parientes por consanguinidad en línea directa o en línea colateral, dentro del segundo grado, del otro cónyuge o conviviente[54]. Lo dicho, como ya he avanzado, no excluye que se pueda instituir heredero a un tercero ajeno al mencionado círculo familiar, aunque el preámbulo, al aludir, precisamente, a los

[53] Este es el caso, por ejemplo, del derecho alemán (§ 2265 BGB). En Galicia, a pesar de que el apartado 1 del art. 187 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (en lo sucesivo, LDCG), parece partir de una legitimación amplia, al afirmar que «[E]s mancomunado el testamento cuando se otorga por dos o más personas en un único instrumento notarial», observamos que el apartado 2 limita el otorgamiento de disposiciones corespectivas a los cónyuges. Finalmente, en el País Vasco, el art. 49 y 172 de la Ley del derecho civil del País Vasco (en adelante LDCPV), *también* lo circunscriben a los cónyuges. En cambio, el art. 406. 3 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas (en lo sucesivo CDFA), no establece ninguna restricción. Este mismo criterio lo sigue la Ley 199 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra (en adelante, CDCFN).

[54] Si partimos, como no puede ser de otra manera, del hecho de que el parentesco por afinidad es el que se establece entre un cónyuge y los parientes por consanguinidad del otro, resulta que el art. 431-2 CCCat dedica dos apartados diferentes, y en parte no coincidentes (las letras c y d), a fijar el grado de parentesco por afinidad. Quiero decir que, mientras la letra c) dispone que se pueden otorgar pactos sucesorios con los parientes por afinidad, con el límite del cuarto grado en la línea colateral, la letra d) establece, también para los parientes por afinidad –a los cuales aquí alude como parientes por consanguinidad del cónyuge– el límite del segundo grado. Esta duplicidad no afecta a la unión estable de pareja, ya que la convivencia no crea parentesco por afinidad y, por lo tanto, podría tener sentido mantener una norma expresa (letra d) para las uniones estables.

heredamientos preventivos, se sigue refiriendo al ámbito familiar más estricto, el de las relaciones paternofiliales.

Pasando a la capacidad de los otorgantes, podemos decir que, en principio, hay una exigencia más elevada en el heredamiento preventivo que en el testamento (notarial), ya que en este basta tener más de catorce años. Es más, la vigente regulación del Código civil de Cataluña ha abandonado la distinción del derecho anterior (art. 67 CS), que diferenciaba entre capacidad para otorgar el heredamiento preventivo−se remitía a la capacidad para contraer matrimonio− y el resto de heredamientos, para los cuales se exigía la mayoría de edad. En efecto, el artículo 431-4 CCCat establece, como regla −es decir, para todo tipo de heredamiento−, que los otorgantes sean personas mayores de edad y que gocen de la capacidad de obrar plena, salvo los que solo tengan la calidad de favorecidos (lo que, en principio, no cabe en los heredamientos preventivos en función de testamento mancomunado) y no estén gravados por ninguna carga, en cuyo caso hay que atenerse a la capacidad natural [55]. En síntesis, para ordenar la sucesión mediante heredamiento preventivo es necesaria una capacidad más elevada de la que se suele exigir para otorgar un testamento mancomunado, en los ordenamientos que los admiten. Sin embargo, esta es una diferencia que, en la práctica, no resulta muy relevante, vista la escasa frecuencia de los testamentos otorgados por personas menores de edad.

Por otra parte, en relación aun con la capacidad, hay que tener presente otro elemento que diferencia los heredamientos preventivos de los testamentos. Me refiero al hecho que, mientras para estos se posibilita que una persona judicialmente incapacitada pueda otorgarlos en intervalo lúcido, si dos facultativos aceptados por el notario certifican que el testador tiene bastante capacidad y lucidez en el momento de testar (art. 421-9 CCCat), eso no es posible en los pactos sucesorios, incluidos, obviamente, los otorgados con carácter preventivo.

4.4. Requisitos de forma

Desde el punto de vista de las exigencias formales, el heredamiento preventivo y el testamento presentan también algunas diferencias. En efecto, mientras que, para los pactos sucesorios, el artículo 431-7.1 CCCat exige la escritura pública como requisito de validez, para el testamento, en cambio, aparte de la forma notarial (en sus variantes de testamento abierto o cerrado), se admite también la forma ológrafa.
Esta es una diferencia que, en principio, tampoco resulta perturbadora para la asimilación funcional que se pretende entre los heredamientos preventivos y los testamentos mancomunados, sobre todo si tenemos en cuenta, nuevamente, que buena parte de los

[55] La menor exigencia de capacidad vendría justificada por el hecho de que para el otorgante favorecido por el heredamiento se puede considerar un pacto jurídicamente neutro, en el sentido que no le genera obligaciones, sino que solo vincula al causante. Cf., en relación con el derecho alemán, MUSIELAK (2004, p. 1709). Esta regla recuerda lo previsto en el art. 531-21.1 CCCat para la aceptación de las donaciones puras. En caso de que el pacto sucesorio contenga gravámenes, entiendo que se tiene que aplicar, por analogía, lo que determina el apartado 2 de este precepto, que admite la aceptación por representante legal, y no el inciso primero del art. 431-4 CCCat, que está pensado más específicamente para el causante. Con respecto a la capacidad del tercero favorecido, hay que decir que es irrelevante en el momento del otorgamiento y será en el momento de apertura de la sucesión cuando haya que atenerse a las normas generales sobre aceptación y repudiación de la herencia (art. 461-9).

ordenamientos que admiten el testamento mancomunado lo limitan exclusivamente a la forma notarial abierta[56].

La razón por la cual se suele excluir el testamento mancomunado en forma ológrafa radica en las dificultades que presenta la exigencia que esté escrito por el testador, que no se puede limitar a firmar lo que haya escrito otro. Sin embargo, la forma ológrafa la admite el derecho aragonés con algunas matizaciones y habiendo recibido la crítica de la doctrina más autorizada[57]. Concretamente, el artículo 411 CDFA –inspirándose probablemente, en el § 2267 BGB– dispone que basta que todo el testamento haya sido escrito por uno de los testadores, haciendo constar el año, el mes y el día, y que el otro declare, igualmente escribiéndolo de su mano, antes de las firmas de ambos, que quiere que también valga como testamento suyo, firmando todas las hojas y al final. Muerto uno de los testadores, el testamento debe adverarse y protocolizarse.

Todo ello, en el bien entendido de que, allí donde se admite el testamento mancomunado, se le suelen aplicar las mismas reglas que rigen para el unipersonal, con la particularidad, claro está, que en aquel la unidad de acto se traduce en que todos los testadores deben concurrir al otorgamiento manifestando su voluntad, sin interrupción, en el mismo intervalo temporal.

4.5. Contenido

Es en relación con el contenido donde, en principio, deberían surgir menos dudas sobre la equiparación que se pretende entre los pactos sucesorios preventivos con pluralidad de causantes y los testamentos mancomunados, dado que la regla de la que parte el artículo 431-5 CCCat es que en pacto sucesorio, «[s]e puede ordenar la sucesión con la misma amplitud que en testamento»[58].

Ahora bien, a pesar de la literalidad del precepto, la asimilación de contenidos no es absoluta, ya que después de concretar que los otorgantes pueden hacer heredamientos y atribuciones particulares —incluido el usufructo universal— y sujetar todas estas disposiciones a condiciones[59],

---

[56] Este es el caso, por ejemplo, del art. 189 LDCG y también el art. 173 LDCPV, en relación con el Fuero Civil de Guipúzcoa. En cambio, para Vizcaya, el art. 49 LDCPV y para Navarra la Ley 199 de la Compilación tan solo exigen que el testamento sea notarial. .

[57] LACRUZ BERDEJO (1992, p. 614), sostiene que el testamento ológrafo no se adecua al testamento mancomunado aragonés, que, por otra parte, no había existido históricamente. Opina que solo encajaría si se escribiera dos veces (una para cada testador), con fecha duplicada y firma de ambos.

[58] Con respecto al negocio jurídico testamentario, el art. 421-2 CCCat dispone que «[E]n testamento, el causante ordena su sucesión mediante la institución de uno o más herederos y puede establecer legados y otras disposiciones para después de su muerte».

[59] Conviene recordar, aunque sea de paso, que la posibilidad de poner condiciones a los heredamientos plantea la cuestión de sí admiten la condición resolutoria, es decir, si rige la regla del art. 423-12 CCCat según la cual se tienen por no formuladas en la institución de heredero la condición resolutoria y los plazos suspensivo y resolutorio. PUIG FERRIOL (1990, p. 147), considera dudoso que se puedan aplicar las reglas de la condición resolutoria, argumentando que la sucesión contractual es ajena al derecho romano. En mi opinión, hay que distinguir según la condición deba cumplirse en vida del causante o después de la muerte. En el primer caso, es posible dejar sin efecto el pacto sucesorio si se cumple la eventualidad prevista en el pacto reversional (art. 431-27.1 CCCat), ya que, entonces, los bienes tienen que retornar al heredante y el favorecido deja de tener la calidad

sustituciones, reversiones o prohibiciones de disponer, así como designar albacea, administrador y contador partidor, más adelante, el artículo 431-7 CCCat lo matiza claramente.

En efecto, este precepto acaba de completar el contenido posible del pacto sucesorio o, para ser más precisos, de la escritura pública, afirmando que puede contener estipulaciones propias del protocolo familiar y de otras estipulaciones sucesorias, pero excluyendo que pueda contener disposiciones de última voluntad, lo que significa, por ejemplo, que no caben los legados.

A tales efectos, hay que recordar que una disposición de última voluntad, por contraposición a los pactos sucesorios (que, siendo negocios *mortis causa*, en principio no son de última voluntad), es aquella mediante la que el causante ordena, con carácter revocable, el destino de su patrimonio para después de la muerte; dicho en otras palabras y como indica su nombre mismo, se caracteriza por el hecho de que quien la otorga puede cambiar de voluntad, mientras viva. De ahí que, como los pactos sucesorios preventivos son revocables, nos tengamos que preguntar si la mencionada prohibición de contener disposiciones de última voluntad rige también para las escrituras en las que se estipula ese tipo de pacto. Según mi opinión, la respuesta debe ser negativa; es decir, cabe que en la misma escritura que los incorpora, los cónyuges, cuando instituyen contractualmente heredero, hagan una o más atribuciones particulares revocables a favor de distintas personas, ya que los heredamientos preventivos son, en sí mismos, verdaderos negocios de última voluntad y, por lo tanto, igualmente revocables. Todo ello, aparte de que la escritura pública del heredamiento preventivo pueda incluir un contenido no sucesorio, como puede ser el reconocimiento de un hijo o la designación de tutor, entre otros.

Ahora bien, no podemos perder de vista que los pactos sucesorios preventivos siguen siendo un convenio sobre la sucesión futura y, por lo tanto, que responden a un esquema típicamente contractual. De este modo, la disposición particular revocable no podrá ser, en sentido propio, un legado (entendido como una declaración autónoma e individual que, según el artículo 427-1 CCCat, solo cabe en testamento, codicilo o memoria testamentaria), sino que, en su caso, debería incluirse como atribución particular, y por lo tanto acordada, también de carácter preventivo.[60]

Respecto al contenido accesorio de los pactos sucesorios, es decir, las posibles cargas que se puedan imponer a los favorecidos (por ejemplo, la de tener cuidado y atención del otro otorgante o de terceros, a las que alude el art. 431-6.2 CCCat), me limitaré a destacar la escasa relevancia que ello puede tener en los heredamientos preventivos (si las cargas se tienen que cumplir en

---

de heredero; en cambio, una vez muerto, deben aplicarse las mismas reglas para la sucesión testamentaria y, por lo tanto, como en esta, la condición resolutoria deberá tenerse por no formulada (art. 411-3.2 CCCat), a menos que se haya configurado como una sustitución fideicomisaria. En relación con la condición suspensiva, la duda se podría plantear respecto de sí la muerte del instituido antes del cumplimientode la condición transmite algo a sus sucesores. Al respecto hay que tener presente que los art. 431-24 y 431-30.3 CCCat disponen que el pacto sucesorio se convierte en ineficaz por premoriencia del favorecido, a menos que se haya convenido lo contrario o se trate de una institución a favor de un descendiente del causante y aquel premuera dejando descendientes llamados; solo en este último caso el mismo derecho se transmite condicionado a los herederos.

[60] Este es, según mi opinión, el sentido que hay que dar a la afirmación del preámbulo donde se admite que, a veces, las disposiciones preventivas pueden acompañar útilmente a otras disposiciones irrevocables otorgadas en un mismo instrumento.

vida del causante), ya que chocan con la posibilidad de que sean revocados en cualquier momento.

4.6. Causas de ineficacia: nulidad, revocación y crisis matrimonial o de pareja

En este apartado, analizaré, en primer lugar, la ineficacia que deriva de la concurrencia de alguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 431-9 CCCat y si se puede distinguir entre la nulidad que pueda afectar al pacto sucesorio propiamente dicho y la de sus disposiciones; en segundo lugar, abordaré específicamente la problemática que plantea la revocación unilateral de los pactos preventivos, y, finalmente, me referiré muy brevemente a los efectos que, en relación con los heredamientos otorgados a favor del cónyuge, del conviviente en pareja estable o de los parientes de estos, plantea la crisis matrimonial o de pareja.

A. Nulidad del pacto y de sus disposiciones

Sin que ahora debamos entrar en el examen de si alguna de las causas de nulidad que contiene el referido artículo 431-9 CCCat podría encajar en la categoría, por otra parte poco precisa, de la inexistencia del negocio, se ha advertir, antes de nada, que el legislador catalán ha establecido un régimen de nulidad de los pactos sucesorios muy parecido al de los testamentos (art. 422-1 y 422-2 CCCat). Es decir, como en estos, el Código distingue entre nulidad del negocio y de las disposiciones que contiene, hecho que, ya lo adelanto ahora, no se aviene con la naturaleza convencional de los pactos sucesorios que, vuelvo a insistir, está presente también en los otorgados con carácter preventivo.

La primera causa de nulidad que enumera el artículo 431-9 CCCat es que el pacto no se corresponda con ninguno de los tipos legalmente previstos. Ello quiere decir que, aunque el libro cuarto del Código civil de Cataluña ha extendido de forma muy notable el alcance de la sucesión contractual (eliminando, por ejemplo, la exigencia de capítulos y ampliando los sujetos que la pueden pactar), los pactos sucesorios todavía se siguen concibiendo como una modalidad excepcional de sucesión. Es en este sentido que se puede afirmar que el artículo 411-7 CCCat, que mantiene una redacción prácticamente idéntica a la del derogado artículo 7 CS, es una norma imperativa y, como tal, su infracción debería comportar *ope legis* la nulidad absoluta de los pactos sobre sucesión no abierta que no sean los que admite el Código. Lo dicho significa, por lo tanto, que no pueden ser objeto de convalidación ni de sanación y que cualquier interesado podrá hacer valer judicialmente la nulidad y el juez apreciar, incluso, de oficio.

Dicho esto, lo cierto es que el artículo 431-10 CCCat, lejos de concebir estos casos como supuestos de nulidad absoluta, establece que «solo» están legitimados para alegarla los otorgantes del pacto. Efectivamente, este último precepto, aparte de distinguir entre si la acción de nulidad se interpone antes de la apertura de la sucesión o una vez esta ya se ha abierto, diferencia también según la nulidad derive de la falta de capacidad o la existencia de algún vicio del consentimiento en el otorgamiento del pacto o disposición concreta, o bien se trate de otra causa diferente. En el primer caso, tan solo se legitima al otorgante que ha incurrido en la falta de capacidad o ha sufrido el vicio, que ha de impugnar el pacto en el plazo de cuatro años desde la recuperación de

la capacidad o desaparición del vicio y, en el caso de error, desde el otorgamiento del pacto. En cambio, si la nulidad se fundamenta en una causa diferente, como puede ser que el pacto no se corresponda con ninguno de los tipos previstos en el Código (reitera el art. 411-7 CCCat, antes aludido), que haya sido otorgado por personas que no están unidas por alguno de los vínculos familiares previstos en el artículo 431-2 CCCat, o que se contenga en documento privado (art. 431-7 CCCat), la legitimación corresponde, como decía, a cualquiera de los otorgantes, lo cual choca con el régimen propio de la nulidad absoluta, que parecería más apropiado en estos casos.

Ante esta disyuntiva y a pesar de la literalidad de los artículos 431-9 y 431-10 CCCat, entiendo que se impone el carácter imperativo de las normas que, respectivamente, restringen los pactos sucesorios a los tipos legalmente previstos, fijan el círculo de personas que pueden intervenir como otorgantes y exigen la escritura pública, hecho que conduce, necesariamente, a aplicar las reglas de la nulidad absoluta en caso de infracción. Lo dicho significa que la ineficacia del pacto sucesorio por estas causas se produce, en principio, sin necesidad de ejercitar ninguna acción, ni que la autoridad judicial declare la nulidad. Por la misma razón, en este ámbito no debe admitirse la prescripción ni la caducidad. Y ello tanto si ya se ha producido la muerte del causante y consiguientemente se ha abierto la sucesión, como si no.

Con respecto a la distinción entre los vicios de la voluntad que afectan el pacto y los que afectan a sus disposiciones, hay que decir que, a diferencia de lo que sucede en el testamento, es muy difícil hacer esta separación. Lo mismo debe decirse si el pacto o heredamiento afecta a dos o más sucesiones, ya que el acuerdo de voluntades constituye una unidad inseparable que integra un único consentimiento contractual, es decir, solo hay un contrato sucesorio que afecta a la sucesión de diversas personas.

Por otra parte, comparándolo nuevamente con el testamento, observamos que en este se parte del hecho de que, como no adquiere valor negocial hasta la muerte, el carácter revocable hace innecesario impugnarlo por causa de nulidad en vida del causante, lo que no quiere decir que, si el testador no lo revoca, deba considerarse válido, ya que, abierta la sucesión, lo podrán impugnar todas aquellas personas que se podrían beneficiar de la declaración de nulidad (art. 422-3.1 CCCat). Partiendo de esta premisa, nos podemos preguntar si este mismo razonamiento es trasladable al heredamiento preventivo y, por lo tanto, si la acción de nulidad pierde su razón de ser en vida del otorgante, sobre la base que también puede dejarlo sin efecto en cualquier momento. En principio, me inclino por la afirmativa, ya que, incluso en el caso de que haya transcurrido el plazo que fija la ley para impugnar, el heredante siempre podrá dejarlo sin efecto acudiendo a la vía de la revocación.

Sin embargo, no lo ha entendido así el legislador catalán, ya que vincula la interposición de la acción por parte de las personas a las cuales, una vez abierta la sucesión, puede beneficiar la declaración de nulidad, al hecho de que no haya caducado para el causante (art. 431-10.3 CCCat). Por consiguiente, se echa de menos una previsión, como la que hay en sede testamentaria (art. 422-3 CCCat), en la que se establezca que dichas personas pueden impugnar el heredamiento

otorgado con falta de capacidad o concurriendo algún vicio de la voluntad, sin condicionarlo al hecho de que no haya transcurrido el plazo que el causante tenía para impugnarlo en vida.

Todo ello dando por supuesto que, dado que la finalidad del heredamiento preventivo unilateral es evitar la sucesión intestada, no se podrá dejar sin efecto mediante el otorgamiento de un testamento meramente revocatorio.

B. Revocación

El hecho de que un heredamiento se pacte con carácter preventivo comporta, como es sabido, que el heredante pueda dejarlo sin efecto otorgando un testamento posterior, que tendrá que ser notarial y abierto, u otro pacto sucesorio (art. 431-21.1 CCCat). Y si se trata de un heredamiento preventivo con pluralidad de causantes, que cada uno de ellos, unilateralmente y sin necesidad que concurra ninguna causa legal de revocación, pueda dejarlo sin efecto revocando las propias disposiciones.

Es fundamental destacar que, para que la revocación sea eficaz, el apartado 2 de este mismo precepto exige que, a menos que los otorgantes lo excluyan, quien revoca lo notifique notarialmente a los demás otorgantes. Esta es una norma que, en la forma en la que está redactada, incluye los heredamientos preventivos con un solo causante, pero todo indica que se incorporó pensando precisamente en los heredamientos preventivos con pluralidad de causantes[61], es decir, aquellos que pueden cumplir la función propia de los testamentos mancomunados, ya que es en estos donde realmente tiene más sentido porque evita que un otorgante pueda actuar defraudando la confianza del otro. Así, el que no ha revocado, enterado de la actuación del otro, puede decidir qué destino dar a los bienes objeto de la disposición que él mismo otorgó en aquel pacto sucesorio[62].

Por lo que respecta específicamente a la revocación de los heredamientos preventivos con pluralidad de causantes —dando por hecho, lógicamente, que, de mutuo acuerdo, pueden dejar sin efecto o modificar las disposiciones que contiene (art. 431-12 CCCat)—, se plantean dos cuestiones de especial relevancia y que el Código no resuelve, al menos de forma expresa. Me refiero, por una parte, a si, además de las propias disposiciones, la revocación de uno afecta también a las disposiciones referidas a la herencia de los otros otorgantes, y, por otra, si la muerte de uno de los otorgantes comporta o no que el sobreviviente ya no pueda revocar su disposición.

Con respecto a la primera cuestión, es decir, la relativa al alcance de la revocación hecha por uno de los otorgantes, el Código no establece ninguna previsión expresa, pero entiendo que, por

[61] Es más, del mismo modo que en el heredamiento preventivo con un solo causante el heredante puede disponer de sus bienes, en vida, por cualquier título, tal como veremos después que ha admitido el TSJC (v. nota 75), también debería poder revocarlo en cualquier momento, incluso sin necesidad de comunicarlo a nadie, como, de hecho, pasaba en el derecho anterior.

[62] No hay, sin embargo, una previsión expresa sobre qué pasa si la notificación no se ha podido hacer efectiva porque, por ejemplo, se desconoce el paradero del otro otorgante. En este punto me inclino, una vez más, por la aplicación analógica del artículo 431-15 CCCat, que prevé que se debe acudirse a la vía judicial.

analogía con lo que dispone el artículo 431-13.4 CCCat en relación con la revocación por causa de indignidad, no solo se proyecta sobre las disposiciones propias, sino que también deja sin efecto las hechas por el otro. El principio que subyace en esta regla es el carácter interrelacionado propio de todas las disposiciones que integran cualquier pacto sucesorio.

De hecho, este es el efecto que, en el derecho comparado, se prevé también para el testamento mancomunado de tipo correspectivo, respecto del que se entiende que las estipulaciones del otro testador (el que no ha revocado) quedan ineficaces desde el momento que el primero revoque[63], excepto, claro está, que del mismo testamento resulte lo contrario.

Sin embargo, no se puede decir que haya una coincidencia exacta entre la revocación regulada en el artículo 431-21 CCCat para los heredamientos preventivos y la de los testamentos. Quiero decir que, en relación con los heredamientos preventivos, la palabra revocación no debe entenderse en su significación estricta, ya que, en principio, lo que hacen el testamento o el pacto sucesorio posteriores es evitar que se dé uno de los presupuestos que determinan la efectividad del heredamiento preventivo[64]: morir sin haber instituido heredero testamentario o contractual[65].

Teniendo en cuenta que, con carácter general, la función del heredamiento preventivo es evitar la sucesión intestada, debe entenderse que, aunque el artículo 431-21 CCCat no lo diga, el testamento con el que se pretende dejar sin efecto el heredamiento preventivo, ha de ser válido y también eficaz[66]. Es decir, si, llegado el caso, el testamento es nulo, lo es la institución de heredero o se convierte en ineficaz por cualquier otra causa (como la preterición errónea, la premoriencia, la indignidad o la renuncia), la herencia deberá deferirse a la persona instituida inicialmente en el heredamiento preventivo. Entonces, el pacto sucesorio, para decirlo gráficamente, recuperará la función que le es propia y producirá los efectos para los que institucionalmente ha sido concebido.

Ahora bien, una interpretación teleológica de la norma lleva a entender que este criterio es válido para los heredamientos preventivos unilaterales, pero no para los que tienen pluralidad de causantes, ya que la finalidad de estos últimos no es evitar e*l ab intestato*, sino, simplemente, permitir que dos o más personas puedan disponer conjuntamente de las respectivas sucesiones en un mismo acto y con carácter revocable. Por ello, en este caso, la revocación se configura como una declaración de voluntad unilateral y recepticia, en el sentido que el efecto revocatorio del

[63] Pueden citarse, por ejemplo, el artículo 421.4 CDFA, la Ley 201 a) 2) CDCFN y el artículo 191 LDCG.

[64] Una visión parecida, aunque construida a partir de la técnica de las condiciones del negocio, la da la anteriormente mencionada STSJC de 12 julio 2001, según la cual: «si se cumple la condición –que el heredante designe heredero testamentario o en heredamiento puro– el heredamiento preventivo se convierte en ineficaz; si la condición no se cumple, el heredamiento preventivo produce todos los efectos que le son propios».

[65] LÓPEZ BURNIOL (1994, p. 396). Lo dicho significa, como ya he avanzado, que un testamento meramente revocatorio no puede dejar sin efecto el heredamiento preventivo, porque abocaría directamente a la sucesión intestada (art. 422-9.5 CCCat), que es lo que precisamente se quiere evitar con este tipo de heredamiento. En el mismo sentido se pronuncian BOSCH CARRERA(2013, p. 119) y ESQUIROL JIMÉNEZ (2008, p. 105).

[66] Por el contrario, sí que lo prevé el art. 422-9.2 CCCat para la revocación del testamento, hecho que ha sido criticado por un sector de la doctrina.

heredamiento preventivo debe entenderse producido en el momento que tiene lugar la notificación notarial a los otros otorgantes, con independencia que, después, el testamento o el heredamiento sean o no eficaces[67], lo que significa que, apartándose de la finalidad histórica de los heredamientos preventivos, puede suceder que los otorgantes lleguen a morir *ab intestato*[68].

La cuestión resulta más compleja cuando lo que se pretende con la disposición *mortis causa* unilateral posterior no es revocar sino simplemente modificar la propia disposición contenida en el heredamiento preventivo mutual. Digo esto porque no es lo mismo que la modificación consista, por ejemplo, en favorecer todavía más al otro otorgante, o, por el contrario, que se le imponga algún tipo de limitación. Ninguno de los dos casos está previsto en nuestro ordenamiento, sin embargo, en el primero entiendo que, como las expectativas del otro otorgante en nada resultan perjudicadas, la modificación será plenamente eficaz. En cambio, en el segundo caso, es decir, cuando lo que se pretende es introducir cargas o limitaciones a la institución (una sustitución fideicomisaria, por ejemplo), sí que se afecta negativamente a las expectativas del otro otorgante. Por eso entiendo que resulta aplicable el régimen de la revocación –podríamos decir que parcial− lo que implica que la disposición modificativa, para que sea eficaz, deba notificarse notarialmente[69] al otro otorgante del pacto sucesorio, el cual podrá manifestar su consentimiento y, si no lo hace, deberá entenderse que su disposición queda sin efecto, como ineficaz debe considerarse también, por lógica, la disposición que se pretende modificar.

Por otra parte, la alusión que hace este mismo precepto al hecho de que los heredamientos preventivos se pueden dejar sin efecto mediante el otorgamiento de un nuevo pacto sucesorio, a pesar de la generalidad de los términos con los que está redactado, hay que descartar que pueda tratarse de un pacto de atribución particular, porque este solo comporta la exclusión del heredamiento del bien o bienes que son objeto de él, sin afectar a la institución de heredero anteriormente estipulada. Sin embargo, en la medida en que implica un acto de disposición a título gratuito, será de aplicación el mismo régimen que para este tipo de disposiciones prevé el artículo 431-25.3 CCCat (me remito, por tanto, a lo que luego se dirá en el apartado 4.7).

Pasando a la segunda cuestión, es decir, si, muerto uno de los otorgantes, el sobreviviente puede revocar el pacto preventivo en el que instituye heredero a un tercero, una interpretación lógica permite entender que la muerte del primero extingue la facultad de revocar y, en consecuencia, que el sobreviviente ya no puede cambiar su voluntad. Y eso no solo porque, muerto el otorgante, ya no es posible la notificación, sino porque esta es la regla que también se desprende del artículo 431-12.1 *in fine* CCCat, cuya aplicación analógica entiendo apropiada en este caso, al no haber una norma expresa, como la que, en el derecho alemán, establece el § 2271 (2) BGB para el testamento mancomunado, según la cual «el derecho a revocar se extingue con la muerte del

[67] De lo contrario, se podría cuestionar por qué hay que notificar el otorgamiento del testamento o pacto sucesorio posteriores al otro otorgante y no, en cambio, la aceptación del instituido heredero (que, según esta teoría, sería lo único que revocaría efectivamente el heredamiento preventivo).

[68] Así lo entendía también, para el Código de sucesiones, DELGADO ECHEVERRÍA (1994, p. 290).

[69] En este caso la notificación, lógicamente, deberá incluir una copia del documento que contiene la nueva declaración de voluntad.

otro cónyuge», sin perjuicio, claro está, que la pueda impugnar si concurre causa de nulidad[70]. Así, pues, de la misma manera que la muerte de cualquiera de los otorgantes extingue la facultad de modificar y de resolver los pactos sucesorios de mutuo acuerdo, el sobreviviente que haya instituido preventivamente a un tercero ajeno al pacto tampoco podrá revocar su disposición integrada en el heredamiento preventivo. Es la misma solución, que, como forma de evitar actuaciones desleales y fraudulentas respecto de las disposiciones vinculadas o correspectivas, prevén algunos de los ordenamientos que admiten el testamento mancomunado[71].

Evidentemente, la cuestión no plantea ningún problema si el heredamiento se limita a un pacto de institución recíproca, ya que, exceptuando que se haya previsto una sustitución fideicomisaria, la muerte de un otorgante comporta que la institución de heredero se concrete definitivamente en el otro y, por lo tanto, que se completen todos sus efectos. En cualquier caso, no habría estado en absoluto de más que el Código hubiera previsto cada una de las posibilidades antes referidas y que, obviamente, las hubiera resuelto de forma expresa.

C. Ineficacia derivada de la crisis matrimonial o de convivencia

El artículo 431-17 CCCat regula los efectos que la nulidad del matrimonio, la separación, el divorcio y también la extinción de una pareja estable tienen sobre los pactos sucesorios en general (es decir, sin distinguir entre los preventivos y los que no lo son).

Se parte del hecho de que, en principio, son circunstancias que, a menos que se haya estipulado el contrario, no alteran la eficacia de la sucesión paccionada. Como ya he avanzado, se exceptúan, precisamente, los heredamientos otorgados a favor del cónyuge o conviviente en pareja estable o de los parientes de estos (entre los cuales también los mutuales y los correspectivos) que se convierten en ineficaces en los mismos supuestos que, para los testamentos, establece el artículo 422-13.1 y 2 CCCat. Ello quiere decir que el ordenamiento catalán entiende que, una vez se rompe la relación conyugal o de hecho, que es la que generaba la confianza que determinó la institución como heredero contractual, ya no hay ninguna razón para mantenerla, de modo que la mencionada institución hereditaria quedará automáticamente ineficaz sin que haya que revocarla. En esto, por lo tanto, tampoco se diferencian de los testamentos.

4.7. Limitación de las facultades dispositivas en vida del causante

Según el artículo 431-25.1 CCCat, el heredamiento simple, y también el cumulativo respeto de los bienes exceptuados de la adquisición de presente y de los que el heredante pueda adquirir después de otorgado, no limitan las facultades de este para disponer de sus bienes a título

[70] Se podría plantear también si, después de muerto el primer otorgante del heredamiento preventivo, puede revocarse o modificarse por alteración de las circunstancias económicas que llevaron a aquella institución. En este punto, el artículo 431-11.1 CCCat nos conduce a una respuesta negativa, ya que, para la modificación de los pactos sucesorios en general, no da ninguna relevancia al cambio de circunstancias,

[71] Aparte del mencionado § 2271 BGB, se puede citar también, en el ordenamiento navarro, la Ley 202 CDCFN.

oneroso[72], ya que rige el principio de la subrogación real. En cambio, con respecto a las disposiciones gratuitas, el apartado 3 de este mismo precepto exige el consentimiento expreso del heredero[73], a menos que se trate de liberalidades de uso o que la disposición sea para satisfacer legítimas o en la cuantía superior que se haya fijado en el heredamiento. La misma limitación dispositiva rige para la constitución de censos, censales o rentas vitalicias.

Como vemos, a diferencia del artículo 99 CS, no menciona los heredamientos mutuales, ni distingue tampoco entre si los heredamientos han sido otorgados con carácter preventivo o no. Sin embargo, estas omisiones no deben llevarnos a concluir, necesariamente, que ambos otorgantes del heredamiento mutual no tengan limitadas las facultades dispositivas, sino todo lo contrario, una vez más, una interpretación lógica permite afirmar que en este punto, el Código civil de Cataluña no ha cambiado de criterio y, por lo tanto que, en vida del heredante, el mutual produce los mismos efectos que el simple. Es decir, a pesar de la incertidumbre sobre cuál será el otorgante que acabará siendo efectivamente heredero, todos, mientras vivan, tienen conferida esta calidad [entendida en el sentido de expectativa], como si hubieran sido instituidos cada uno en un heredamiento simple (art. 431-19 CCCat). Lo dicho significa que no se puede dejar a la decisión libre de cada otorgante la realización de actos dispositivos que disminuyan el contenido económico del patrimonio, como no sea a riesgo de defraudar la expectativa del otro, derivada de la irrevocabilidad de esta institución.

Ahora bien, en caso de que los heredamientos mutuales hayan sido pactados con carácter preventivo, un sector de la doctrina entiende que solo hay una simple vocación sucesoria revocable unilateralmente y, de aquí concluye que no se puede producir ninguna afectación de presente sobre el patrimonio de los heredantes[74]. En esta misma línea, se suele argumentar también que el hecho de que el heredante no pueda disponer, en vida, de sus bienes a título gratuito si no es con el consentimiento del otro no se corresponde con la facultad que deriva del carácter preventivo del pacto sucesorio que, precisamente, permite revocar el heredamiento[75]. Entiendo, sin embargo, que las anteriores consideraciones, que llevan a concluir que las mencionadas limitaciones dispositivas no rigen para el heredamiento preventivo, solo valen para un tipo concreto de heredamiento preventivo, el que contiene disposiciones relativas a un solo causante, pero no para aquellos en los que, como el mutual, hay dos causantes, ya que, entonces, prevalece el carácter interrelacionado de las disposiciones.

---

[72] Históricamente, como afirma PLANAS Y CASALS (1925, p. 298), se partía del principio contrario; es decir, para disponer se exigía que el heredante se hubiera reservado expresamente la facultad de vender y gravar, ya que este poder «de hecho inutiliza el heredamiento, resultando que el hijo tiene un derecho que es o puede ser ilusorio». En cambio, para el heredamiento preventivo [unilateral], este mismo autor (*loc. cit.* p. 328) consideraba que, al tratarse de una institución condicional, es decir, subordinada al hecho de morir sin testamento, no otorgaba ningún derecho al hijo para impugnar las enajenaciones que los padres hubieran hecho en vida.

[73] Hay que entender que la referencia al heredero lo es a la persona que al mismo tiempo es también otorgante del pacto ya que, de acuerdo con el artículo 431-3 CCCat, el tercero instituido no adquiere ningún derecho hasta el momento de la muerte del causante.

[74] LÓPEZ BURNIOL (1994, p. 412).

[75] Así lo argumentó, aunque refiriéndose a un heredamiento preventivo no mutual sometido al régimen de la Compilación de 1960, la STSJC de 12 julio de 2001.

La limitación de las facultades dispositivas a título gratuito evita, como decía, que, sin necesidad de modificar o revocar formalmente el heredamiento, uno de los otorgantes pueda vaciar económicamente su disposición sucesoria, como si se hubiera producido, *de facto*, una revocación[76]. De hecho, la proximidad que hay entre los mencionados actos dispositivos *inter vivos* y la revocación propiamente dicha permite excluir la aplicación del artículo 431-25.4, que legitima el heredero instituido para impugnar los actos dispositivos otorgados en daño o en fraude de heredamiento, y aplicar, por analogía, el artículo 431 -21.2 CCCat[77]. En este sentido podría pensarse en la conveniencia de una futura reforma que, de forma expresa, estableciera que la eficacia del acto de disposición gratuita queda condicionada a la notificación notarial al otro otorgante.

El Código tampoco especifica si el otorgante sobreviviente de un heredamiento preventivo con pluralidad de causantes tiene limitadas o no las facultades dispositivas sobre los bienes que él ha recibido en virtud del mencionado heredamiento y que hayan sido gravados con una institución sucesiva de heredero a favor de un tercero. *Sin embargo, como se trata de una sustitución fideicomisaria, no hace falta que haya ninguna previsión especial, ya que, vista la condición de fiduciario del sobreviviente, quedará afectado por las mismas limitaciones que rigen para el fiduciario (art. 426-36 y ss. CCCat). En cambio, en relación con el patrimonio propio de este, respecto del cual, en virtud del pacto sucesorio preventivo, ha sido instituido heredero un tercero no otorgante del pacto, habría sido aconsejable prever que no pudiera disponer a título gratuito y que la institución preventiva se convirtiera en irrevocable después de la muerte del primer causante*[78]*. En cualquier caso, quiero insistir en el hecho de que el tercero no adquiere ningún derecho a la sucesión hasta la muerte del causante (art. 431-31 CCCat) y, consiguientemente, tampoco puede impugnar los actos dispositivos otorgados en daño o en fraude del heredamiento.*[79]

5. Consideraciones conclusivas

A modo de conclusión, podemos afirmar que, efectivamente, el heredamiento en el que ambos otorgantes, con carácter preventivo, disponen de las respectivas herencias puede desarrollar, en

[76] Es en este sentido que GARCÍA-GRANERO (1998, p. 907), ha podido afirmar que la disposición a título gratuito es, por decirlo así y siempre en sentido figurado, una especie de testamento parcial en lo que se refiere a los bienes que comprende. En el derecho navarro, la Ley 204 CDCFN prevé esta misma limitación dispositiva para el testamento mancomunado. En cambio, el art. 422.2 CCFA y 194 LDCG optan por la ineficacia *ope legis.*

[77] Esta es la interpretación que sugiere ESQUIROL JIMÉNEZ (2008, p. 101), necesidad de notificación que otros, como BOSCH CARRERA (2013, pp. 116 y 119), han basado en el principio de la buena fe contractual, hoy positivizado en el artículo 111-7 CCCat.

[78] *Para el País Vasco, el art. 178.1 LDCFPV establece que «El supérstite no podrá disponer a título gratuito de los bienes que se hayan señalado como objeto de las susodichas disposiciones correspectivas, salvo en favor de la persona o personas que se hubieren designado como beneficiario o beneficiarios de las mismas en el testamento mancomunado».* Por su parte, para Navarra, la Ley 203 b) CDCFN admite que el sobreviviente pueda disponer a título oneroso, pero no, en cambio, a título gratuito.

[79] Vid. en este sentido, FERRER I RIBA (2009, p. 1066), donde lo argumenta a partir del artículo 431-25.2 CCCat, según el cual se puede convenir con el instituido que sea otorgante del pacto sucesorio la transmisión de la empresa o de las acciones o participaciones (art. 431-30 CCCat).

la práctica, las funciones que son propias del testamento mancomunado. La limitación de las personas que lo pueden pactar, la exigencia de la mayoría de edad y el requisito de la escritura pública no constituyen ninguna diferencia relevante respecto de este tipo testamentario, sino al contrario, perfilan un régimen jurídico equiparable a lo que en otros ordenamientos se prevé para los testamentos conjuntos, particularmente los ordenamientos que lo restringen a los cónyuges y a la forma notarial abierta, que resultan ser mayoritarios. Y, con pocas especificidades, la misma equivalencia se puede hacer respecto del régimen de ineficacia y, sobre todo, de la revocación, de la limitación *inter vivos* de las facultades dispositivas, así como de las causas de ineficacia.

Si esto es así, y partiendo de la constatación de que, según hemos visto al inicio del presente trabajo, proliferan los testamentos individuales en los que los cónyuges otorgan disposiciones correspectivas, lo lógico sería que, en la práctica, la nueva regulación hubiera llevado a un aumento significativo de estos heredamientos. De momento no ha sido así, sino que el incremento de los heredamientos ha sido muy moderado. De acuerdo con los datos facilitados por el Colegio de Notarios de Cataluña, en el año 2009, que es cuando entró en vigor el libro cuarto del Código civil de Cataluña, se otorgaron 73 heredamientos sin atribución de bienes (de los cuales no se puede precisar cuántos lo estuvieron con carácter preventivo); de aquí se pasó a 114 en el año 2010, 168 en el 2011, 251 en el año 2012 y 293 en el año 2013.

Aunque, como se puede ver, el número de heredamientos se ha multiplicado por cuatro, no deja de ser una cantidad bastante modesta, por no decir insignificante, sobre todo si la ponemos en relación con el número de testamentos unipersonales, ya que la distancia que los separa sigue siendo abismal. En efecto, en este mismo periodo de tiempo en Cataluña se otorgaron en torno a 107.000 testamentos cada año.

Lo anterior se explica, probablemente, por el desuso en el que cayó la sucesión contractual desde mediados del siglo XX y que, a pesar de la renovada regulación, ha persistido en la actualidad, habiendo resultado insuficiente el llamamiento que hace el preámbulo a que los heredamientos preventivos pueden ocupar el lugar de los testamentos mancomunados, ya que, al no haber una expresa referencia normativa, ha pasado totalmente desapercibida. Es decir, los heredamientos siguen siendo hoy una institución prácticamente desconocida para la ciudadanía, el solo nombre de la cual genera un cierto recelo[80] que se traduce en el hecho de que, de forma todavía rutinaria, los cónyuges sigan optando por el testamento individual.

En derecho, solemos decir que los actos o negocios jurídicos son lo que son con independencia del nombre que se les dé, o, dicho en términos más coloquiales, que el nombre no hace la cosa. Por lo que se ve, no lo perciben así los testadores, ya que, al parecer, entienden fácilmente qué es un testamento y qué significa otorgarlo, pero, en cambio, ignoran o, cuando menos, se les hace difícil entender que el otorgamiento de un heredamiento preventivo especialmente diseñado se asimile al testamento mancomunado. Quiero decir que no es inverosímil pensar que si la misma

[80] Desde otra perspectiva, la de la eficiencia económica, NAVAS NAVARRO (2011, p. 125), auguraba también la poca incidencia práctica que acabaría teniendo la sucesión paccionada, sobre la base de los mayores costes que, en su opinión, presenta en relación con el testamento ordinario.

regulación que hoy configura el heredamiento mutual preventivo hubiera recibido el nombre de testamento conjunto o mancomunado, la cifra de otorgamientos sería sensiblemente más elevada.

6. Bibliografía

Manuel ALBADALEJO GARCÍA (1990), "Comentario al artículo 669 CC", en Manuel ALBADALEJO GARCÍA (Dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales,* Tom. IX, vol. 1º-A, Edersa, Madrid, pp. 103-113.

Biondo BIONDI (1960), *Sucesión testamentaria y donación*, traducido del italiano por Manuel FAIREN, 2ª ed., Bosch, Barcelona.

Manuel DE BOFARULL Y DE PALAU (1878), *Tratado completo del Derecho romano en cuadros sinópticos según el órden general de la Instituta*, cuadro 43, Imprenta de la Renaixensa, Barcelona.

Antoni BORRELL I SOLER (1944), *Derecho civil vigente en Cataluña*, 2ª ed., Bosch, Barcelona.

Antoni BOSCH CARRERA (2013), "Aspectos civiles de los pactos sucesorios", a Javier VALLE ZAYAS /Juan Antonio PÉREZ RIVARÉS / José Ramón SALELLES (Dirs.), *Estudios sobre Derecho de la empresa en el Código de Cataluña*, Bosch, Barcelona, pp. 116 y 119.

Guillem Maria DE BROCÀ (1918), *Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil y exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia*, Herederos de Juan Gili, Barcelona.

Guillermo María DE BROCÀ Y MONTAGUT / Juan AMELL Y LLOPIS (1886), *Instituciones del derecho civil catalán vigente, ó sea exposición metódica y razonada de las leyes, costumbre y jurisprudencia de los autores y de la antigua Audiencia del Principado; completada con la doctrina del Tribunal Supremo*, T. II, Barcelona.

Jaume CANCER (1670), *Variarum Resolutionum Iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Principatus Cathalauniae.* Pars tertia, cap. VII, núm. 136, 137, 143 y 150, Lugduni.

Josep COMES (1655-1722), *Viridarium Artis Notariatus sive tabellionum viretum ex odoriferis doctorum et huiusce Artis Authorum floribus quibusque optionibus aquis perutiliter faecundatum,* Vol. I, 1704, ex typographia Francisci Oliva, Girona, Vol. II, 1706.

Arturo CORBELLA (1906), *Manual de Derecho catalán*, Imp. de Viuda de Vidiella y Pablo Casas, Reus.

Eugenio DE TAPIA (1875), *Teoría del arte de notaría*, 3ª ed., Manuel Saurí y Eudaldo Puig, Barcelona.

Bonaventura DE TRISTANY (1701), *Sacri svpremi regii senatvs Cathaloniae decisiones,* Barcinone: ex typ. Raphaelis Figverò, vol. III, dec. XCI, per totum.

--- (1688), *Sacri Supremi regii senatvs Cathaloniae decisiones*, T. II, Dec. LI i LII, Barcelona, pp. 368 y ss.

Jesús DELGADO ECHEVERRÍA (1994), «El testamento mancomunado aragonés», en Àrea de Dret Civil (Coord.) Universitat de Girona, *Setenes Jornades de Dret Català a Tossa* (setembre 1992), PPU SA, Barcelona, pp. 289-299.

Joan EGEA FERNANÀNDEZ/Joan MARSAL GUILLAMET (1994), «L'aportació dels notaris a la ciencia jurídica catalana (segles IX a XIX)». Fundació Noguera, *Actes del I Congrés d'Història del notariat català*, Barcelona, (Reproduce la «Nota de Redacció» de la revista La Notaría «Consultas sobre el Código civil», La Notaría, XXXII, núm. 1627 (1889, 10-6), pp. 12838 y12839).

--- (1994) «L'aportació dels notaris a la ciència jurídica catalana (segles IX a XIX)». Fundació Noguera, *Actes del I Congrés d'Història del notariat català*, Barcelona, (Reproduce: La Circular, publicada en *La Notaría* XXXII, núm. 1665 (1889, 23-XII) pp. 13065-13066).

José Antonio ELIAS (1864), *Manual del Derecho civil vigente en Cataluña*, 2ª ed., arreglada en vista de la legislación vigente hasta el día y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia por Alejandro DE BACARDÍ), Imprenta de Ramírez, Barcelona.

--- (1877), *Derecho civil general y foral de España: ó sea resúmen ordenado de las leyes vigentes en los varios territorios que forman la Monarquía española y de las decisiones del Tribunal Supremo que establecen jurisprudencia; con un apéndice sobre las disposiciones de derecho civil que rigen en las provincias de Ultramar*. T. III, Saturnino Gómez, Madrid/ Gaspar y Homdedeu, Barcelona.

Víctor ESQUIROL JIMÉNEZ (2008), "El heredamiento mutual preventivo: una figura a reconsiderar en la práctica notarial", *La Notaría*, núm. 59-60, pp. 99-109.

Josep FERRER I RIBA (2009), "Article 431-3", en Joan EGEA FERNÀNDEZ/Josep FERRER I RIBA (Dirs.), Laura ALASCIO CARRASCO (Coord.), *Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions,* vol. II, Atelier, Barcelona, pp. 1061-1067.

Werner FLUME (1992), *El negocio jurídico*, traducción de la 4ª ed. (1998) de J. M. MIQUEL GONZÁLEZ i Esther GÓMEZ CALLE, Fundación Cultural del Notariado, Madrid.

Joan Pere FONTANELLA (1719), *Tractatus de pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus*. T-II clausula V, glossa VIII, pars VIII, núm. 35, Lugduni.

Jeronimo GALÍ Y RAMÓN (1682), *Opera artis notariae: theoricam simul, et practicam eruditionem complectentia*, ex typographia Hyacinthi Andreu, Barcelona.

Juan GARCIA-GRANERO (1998), "Leyes 148 a 252 de la Compilación o Fuero Nuevo de Navarra", en Manuel ALBADALEJO GARCÍA (Dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales,* T. XXXVII, vol. 1, Edersa, Madrid., pp. 23-33.

José-Ramón GARCÍA VICENTE (2006), *El testamento mancomunado: razones para la derogación del artículo 669 del Código Civil.* Libro de las XI Jornadas de la APDC, Múrcia.

Martín GARRIDO MELERO (1997), "La agonía del testamento y de las formas testamentarias en el Derecho catalán actual", *RCDI,* núm. 639, marzo-abril, pp. 463-501.

Viçent GILBERT (1772), *Theorica artis notariae, quam Vicentius Gibert notarius publicus de numero Barcinonae offert publicae utilitati,* Typis Francisci Generas, Barcelona (Traducció al castellà).

Benito GUTIÉRREZ (1871), *Códigos ó estudios fundamentales sobre el derecho civil español*, III, 3ª ed., Librería de Sánchez.

Ralf E. HESS (2002), «§10 Erbvertrag», *Münchener Anwaltshandbuch*, C.H. Beck, München.

Lluís JOU I MIRABENT (1994), "El testament en el Codi de successions de Catalunya", en Àrea de Dret Civil (Coord.) Universitat de Girona, *Setenes Jornades de Dret Català a Tossa* (septiembre 1992), PPU SA, Barcelona, pp. 59-88.

José Luis LACRUZ BERDEJO (1992), «Un dictamen y dos sentencias», en José Luis LACRUZ BERDEJO, *Estudios de Derecho privado común y foral. Obligaciones y sucesiones,* T. II, Bosch, Barcelona (publicado en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 1969, pp. 1623-1654).

Juan José LÓPEZ BURNIOL (1994), "Comentario a los arts 99-100", en Lluís JOU I MIRAVENT (Coord.), *Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña*, Bosch, Barcelona, pp. 406-413.

José Manuel LETE DEL RÍO /Marta REQUEJO ISIDORO (1997), "Artículo 137 de la Ley de derecho civil de Galicia", en Manuel ALBADALEJO y Silvia DÍAZ ALABART (Dirs.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,* T.XXXII, vol. 2, Edersa, Madrid.

Joan MARSAL GUILLAMET (2000), *El testament*, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Barcelona.

Tomás MIERES (1621), *Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae.* Pars Secunda, Collatio sexta, cap. 20, núm. 20, Barcelona.

Hans-Joachim MUSIELAK (2004), *Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch*. Erbrech (comentari al § 2275 BGB) Band 9, 4. Auflage, München, Beck.

Susana NAVAS NAVARRO (2011), «Freedom of Testation Versus Freedom to Enter Into Succession,

Agreements and Transaction Costs», en Miriam ANDERSON/ Esther ARROYO, *The Law of Succession: Testamentary Freedom*, Groningen, pp. 105-128.

Josep PELLA I FORGAS (1918), *Código Civil de Cataluña. Exposición del derecho catalán comparado con el Código Civil español*, T. III, Bosch, Barcelona.

Marcus Antonius PEREGRINUS (1600), *Consilia sive Responsa Iuris*, Consilia 66, núm. 12, Frankfurt.

José María PLANAS I CASALS (1925), *Derecho Civil Español común y foral,* T. II, Vol. II, Bosch, Barcelona (Publicado y anotado por Mariano RUBIÓ I TUDURÍ).

Lluís PUIG FERRIOL (1990), "Comentari a l'art. 64 CDCC", en Manuel ALBADALEJO GARCÍA (Dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, T. XXVII, Edersa, Madrid, pp. 145-150.

Acaci Antoni DE RIPOLL (1630), *Variae Iuris Resolutiones*, cap. XII, núm. 238, Lugduni.

Encarna ROCA TRIAS (1974), "Heredamiento preventivo: características. Afinidades con los testamentos pluripersonales de Aragón y Navarra. Inscripción de los heredamientos preventivos. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de marzo de 1973", *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 2, pp. 151 -176.

Ronaldini RUDOLPHINI BONONIENSIS (1565), *Summa Artis Notariae*, Lugduni.

Pau SALVADOR CODERCH /Juan José LÓPEZ BURNIOL (2009), "Comentari a l'article 411-3", en Joan EGEA FERNÀNDEZ/Josep FERRER RIBA (Dirs.), Laura ALASCIO CARRASCO (Coord.), *Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions*, Atelier, Barcelona, pp. 68-71.

Josep SANTDIUMENGE FARRÉ (1994), "El testament mancomunat en el dret alemany: notes sobre la revocació de les disposicions testamentàries", a Àrea de Dret Civil (Coord.) Universitat de Girona, *Setenes Jornades de Dret Català a Tossa* (septiembre 1992), PPU SA, Barcelona, pp. 439-455.

BARTOLI A SAXOFERRATO (1589), *In primam infortiati partem Commentaria. Quibus, praeter Alex. Barb. Seissell. Pom. Nicelli, et aliorum adnotationes, et contrarietatum Conciliationes,* «Lex patris, et filii ff. De vulgari et pupillari substitutione (D. 28, 6, 20)» Augustae Taurinorum, fol. 172, n. 3.